일감부동산법학 | 제32호
2026년 5월 101-156쪽
건국대학교 법학연구소

Ilkam Real Estate Law Review
Vol.32, May., 2026. pp.101-156
The Institute of Legal Studies, Konkuk Univ.

특수법인 설립등기의 이원적 효력과 등기청구권

-설립근거법과 일반법 보충적용의 이원 구조를 중심으로-

A Study on the Legal Basis and Effects of Incorporation Registration of Special Legal Entities

-Focusing on the Dual Structure of Establishing Statutes and the Supplementary Application of General Law-

김 민 규*
Kim, Mingyu

목 차

Ⅰ. 서언
Ⅱ. 법인설립등기의 일반이론과 특수법인의 법적 성질
Ⅲ. 특수법인 설립등기의 현행 규율과 문제 상황
Ⅳ. 특수법인 설립등기의 법적 근거
Ⅴ. 설립등기의 이원적 효력과 등기청구권
Ⅵ. 맺음말

https://doi.org/10.35148/ilsire.2026..32.101
투고일: 2026. 4. 15. / 심사완료일: 2026. 5. 18. / 게재확정일: 2026. 5. 25.

* 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 겸직교수
Adjunct Professor at KAIST Graduate School of Future Strategy

같은 변호사법에 근거하여 설립된 특수법인임에도 대한변호사협회에는 법인등기부가 존재하는 반면 서울지방변호사회에는 존재하지 않는다. 양자는 모두 변호사법에 의해 법인격을 직접 부여받은 특수법인임에도 설립등기 여부가 달리 나타나는 현상은, 특수법인 설립등기의 법적 근거와 효력이 체계적으로 규명되지 않은 데서 비롯된 구조적 문제이다. 현행 규율 체계는 비송사건절차법 제67조 제1항, 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제6조 제3항, 사법등기심의관 선례변경(제3387호)을 통해 특수법인에 대한 설립등기 가능성은 인정하면서도, 그 근거와 효력에 대해서는 명시적 설명을 제공하지 못한다. 그 결과 특수법인이 부동산을 취득·처분하거나 근저당권을 설정하는 과정에서 대표자와 대표권 제한을 등기부를 통해 표준적으로 확인하기 어렵고, 대표권 공시와 대항력 확보라는 등기제도의 핵심 기능이 부동산거래 영역에서 충분히 작동하지 못한다.

본 논문은 이러한 해석론적 공백을 메우기 위하여, 특수법인의 설립근거법 구조와 공법인의 이중적 법적 성질, 5개 직능단체법(의료법·변호사법·변리사법·세무사법·법무사법)의 준용 규정 유무, 비법인사단에 대한 기능별 승인 법제를 종합적으로 분석한다. 이를 토대로 준용 규정이 없는 특수법인에 대해서도 비송사건절차법과 등기규칙, 민법의 일반법적 지위, 입법 누락에 대한 귀납적 논증, 거래안전의 요청을 결합하여 설립등기의 법적 근거를 누적적으로 도출하는 해석론을 제시한다. 나아가 특수법인 설립등기가 설립근거법 차원에서는 법인격의 존재를 전제로 한 공시적 효력을, 민법 제49조·제54조·제60조가 적용되는 사법상 거래 영역에서는 대표권 공시와 대표권 제한의 대항력 확보, 등기사항의 제3자 대항을 가능하게 하는 '거래법적 보충효'를 갖는다는 이원적 효력론을 제시하고, 이 효력을 민법 제33조상의 성립요건적 창설과 구별되는 거래주체성의 보충적 완성으로 위치시킨다. 또한 등기청구권을 특수법인이 설립등기 절차에 접근하여 위와 같은 공시·대항 구조를 작동시킬 수 있게 하는 절차적 권리로 파악하고, 비송사건절차법상 이의신청·항고를 중심으로 등기관서의 거부·직권말소에 대항할 수 있는 구체적 행사 경로를 제시한다. 마지막으로 개별 설립근거법의 준용 규정 명문화와 민법 차원의 확인 규정을 중심으로 한 입법적 개선 방향을 검토함으로써, 특수법인이 부동산거래에서 대표권 공시와 대항력 확보라는 등기제도의 기능에 일관되게 접속할 수 있는 규범적 틀을 제안한다.

[주제어] 특수법인, 설립등기, 설립근거법, 일반법 보충적용, 대표권 공시, 대표권 제한의 대항요건, 등기청구권

Ⅰ. 서언

같은 변호사법에 근거하여 설립된 특수법인임에도, 대한변호사협회는 법인등기부가 존재하고 서울지방변호사회는 존재하지 않는다.[1] 양자 모두 변호사법에 의해 법인격을 직접 부여받은 특수법인이며, 동일한 법률에 근거하여 유사한 조직 구조와 기능을 수행한다.[2] 그럼에도 등기 여부가 법인별로 상이하게 나타나는 이 현상은 단순한 실무상의 우연이 아니다. 이는 설립등기의 법적 근거와 효력이 체계적으로 정리되지 않은 데서 비롯된 구조적 문제이며, 동일 법률·유사 기능의 단체 간에 등기 여부가 상이하게 나타나는 현상이 이를 단적으로 보여준다. 법인등기부가 부재하면 대표자 확인, 대표권 제한의 대항력 확보, 금융거래상 신용 확인, 소송상 법인실체 증명에서 공통된 장애가 발생한다. 이하에서는 이러한 장애를 반복적으로 열거하기보다, 그것이 설립등기의 법적 근거

1) 이에 대해 특수법인으로 보는 근거로서, 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제1조; 변호사법 제64조 제2항, 제78조 제2항. 등기부 존재 여부는 2024. 12. 1. 기준 대법원 인터넷등기소 법인등기부 열람 결과에 의한다. 제64조 (목적 및 설립) ① 변호사의 품위를 보전하고, 변호사 사무의 개선과 발전을 도모하며, 변호사의 지도와 감독에 관한 사무를 하도록 하기 위하여 지방법원 관할 구역마다 1개의 지방변호사회를 둔다. 다만, 서울특별시에는 1개의 지방변호사회를 둔다. ② 지방변호사회는 법인으로 한다. 제78조 (목적 및 설립) ① 변호사의 품위를 보전하고, 법률사무의 개선과 발전, 그 밖의 법률문화의 창달을 도모하며, 변호사 및 지방변호사회의 지도 및 감독에 관한 사무를 하도록 하기 위하여 대한변호사협회를 둔다. ② 대한변호사협회는 법인으로 한다. 변호사법은 변호사회를 단순히 '법인'이라고만 규정하나, 설립과 회원 가입이 법률로 강제된다는 점에서 공법인으로 분류되는 것이 타당하다. 이 점에 관한 상세한 분석은 Ⅱ.3.1 이하에서 후술한다. 이상덕, "변호사회의 법적 성질과 소송형식", 행정법연구 제39호, 행정법이론실무학회, 2014, 41쪽; 송시강, "공법상 법인에 관한 연구", 홍익법학 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2019, 573-621쪽.

2) 독일연방변호사법(BRAO)은 변호사회를 '공법상 단체'로 명시하고 있으나, 한국 변호사법은 '법인'이라고만 규정한다. 다만 양자의 설립·가입 강제 구조와 규제 기능은 실질적으로 유사하다. 독일과의 상세 비교는 Ⅱ.3.2에서 후술한다. 이상덕, "변호사회의 법적 성질과 소송형식", 43쪽 및 48-50쪽 참조.

와 효력에 관한 해석론적 공백에서 비롯된다는 점을 중심으로 논의를 전개한다.[3)]

법인등기부가 부재하면 거래 상대방이 법인의 대표자를 확인할 표준적 수단이 작동하지 않는다. 대표권 제한을 등기할 수단이 없어 대항력 확보가 원천적으로 차단되며,[4)] 금융거래에서의 신용확인과 소송에서의 법인실체 증명[5)]에도 심각한 장애가 발생한다. 나아가 누가 적법한 대표자인지, 어떤 법인인감과 인영이 외부 의사표시를 표상하는지에 관한 표준적 확인 경로도 약화되어, 소송에서는 대표권 흠결을 둘러싼 분쟁이 쉽게 발생한다.[6)]

이 혼선의 원인은 등기 절차 자체의 부재가 아니다. 비송사건절차법 제67조 제1항은 특수법인에 대한 법인등기 규정의 적용을 법률 차원에서 인정하고 있으며,[7)] 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제6조 제3항은

3) 다만 지방변호사회와 대한변호사협회는 동일한 공법상 단체 유형에 속하면서도, 법률이 부여한 구체적 권한의 범위에는 뚜렷한 차이가 있다. 이 차이가 등기 문제에 미치는 영향에 관하여는 Ⅱ.3.1에서 상세히 검토한다. 이상덕, 위의 논문, 43쪽 및 48-49쪽 참조.

4) 대표권 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다(민법 제60조). 판례는 제한의 내용·형태를 불문하고, 등기되지 않은 제한에 대해서는 선의·악의를 가리지 않고 대항할 수 없다는 입장을 일관되게 취하고 있다. 남효순, "민법상 이사의 대표권제한", 서울대학교 법학 제50권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2009, 135-137쪽; 고상현, "비영리법인에서 계약상의 제 문제", 재산법연구 제36권 제4호, 한국재산법학회, 2020, 1쪽 참조. 구별설·비구별설의 상세한 학설 대립에 관하여는 Ⅱ.1.2 및 Ⅴ.2에서 후술한다.

5) 미등기 상태에서의 실체 증명 곤란과 소송상 리스크에 관한 구체적 사례 분석은 Ⅲ.3.4에서 후술한다. 이하 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다308208 판결 참조.

6) 금융기관의 고객확인 실무에서 등기사항증명서가 표준 확인서류로 기능하는 구조와 비등기 단체가 이 과정에서 구조적으로 불리해지는 양상에 관하여는 Ⅲ.3.4에서 상세히 검토한다. 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령 제10조의4, 제10조의5; 금융실명거래및비밀보장에관한법률시행령 제4조의2 참조.

7) 비송사건절차법 제67조 제1항: "이 법 중 법인의 등기에 관한 규정은 민법 및 상법 외의 법령에 따라 설립된 법인의 등기에 대하여도 적용한다. 다만, 그 법령에 특별한 규정이 있거나 성질상 허용되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다."

민법 등기 규정의 보충 준용을 규정하고 있다. 2021년에는 사법등기심의관이 선례변경(제3387호)을 통해 특별법에 등기사항 규정이 없더라도 민법 제49조를 적용하여 등기가 가능하다고 확인하였다.[8] 그럼에도 불구하고 대한변호사협회가 2013년 설립등기를 마치고 이후 312건의 변경등기를 수리받아 온 상태에서, 2021년 특정 등기관이 "변호사법에 등기에 관한 근거 규정이 없으므로 기존 설립등기도 무효의 등기로 추후 직권말소 대상"이라는 이유로 변경등기신청을 각하하는 사태가 발생하였다.[9] 이는 현행 규율 체계가 등기의 가능성(할 수 있다)까지만 확인한 데 머물러, 등기의 법적 근거(왜 할 수 있는가)와 효력(어떤 법적 결과가 발생하는가)을 규명하지 못한 데서 비롯된다. 특히 특수법인이 부동산을 취득·처분하거나 근저당권을 설정하는 경우, 법인등기부의 부재는 대표권 확인과 대표권 제한의 대항력 확보를 원천적으로 차단하여 부동산 거래의 안전을 직접 위협한다. 이 점에서 특수법인 설립등기의 법적 근거와 효력 문제는 부동산등기법과 물권법이 전제하는 공시 체계와도 밀접한 관련을 가진다.

더욱이 이 문제는 특수법인의 사법상 거래에 그치지 않는 함의를 가진다. 대법원은 대한변호사협회를 "위탁받은 공행정사무에 관한 행정주

8) 사법등기심의관 2021. 5. 31. 제3387호(상업등기선례 제202105-3호, 2021. 7. 20. 제정). 종전 선례(상업등기선례 제1-436호)를 변경하여 다음 세 가지를 확인하였다. 첫째, 특별법령이 등기사항을 명시하고 있지 아니한 경우에도 성질에 반하지 아니하는 한 민법 제49조를 적용하여 등기할 수 있다. 둘째, 특별법령에서 '이사' 외에 '협회장, 부협회장, 상임이사 또는 이사장' 등 다른 명칭의 임원을 두고 있는 경우, 성질에 반하지 아니하는 한 민법 제49조 제2항 제8호·제9호의 '이사'에 관한 규정을 준용하여 해당 명칭을 그대로 등기하여야 한다. 셋째, 감사는 민법 제49조 제2항 제8호·제9호의 '이사'와 성질을 달리하므로 해당 특별법령에서 등기사항으로 규정하지 않은 감사를 민법에 근거하여 등기할 수는 없다.

9) 서울중앙지방법원 2021. 4. 15. 자 2021비단10 결정. 이 결정의 판시 내용과 그에 대한 비판적 분석은 Ⅳ.3에서 상세히 검토한다. 이 결정에 대한 판례평석으로 법조신문, 박시형, "[판례평석] 대한변호사협회 법인변경등기신청 각하결정에 대한 이의사건", 2025. 2. 26, <https://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=32801>, 검색일: 2026. 3. 11.

체"로 인정하고 있고,[10] 헌법재판소는 대한변호사협회를 변호사등록에 관한 한 "공법인으로서 공권력 행사의 주체"로 인정한 바 있다.[11] 동시에 대법원은 대한의사협회를 사법상 거래관계의 주체로 인정하였다.[12] 이처럼 동일한 특수법인이 공법인·행정주체이면서 동시에 사법상 거래의 주체로 기능한다는 점은, 설립등기의 법적 성질을 단일한 기준으로 파악하기 어렵게 하는 구조적 원인이 된다.

나아가 이러한 공시·대표권 구조의 미비는 현행 특수법인에 국한되지 않는다. 장차 특별법에 의해 새로운 유형의 법인이 설립되는 경우 — 예컨대 인공지능기본법(2026. 1. 22. 시행)에 따른 운영주체의 설계 — 에도 동일한 구조적 리스크가 재현될 수 있다는 점에서, 본 논문의 분석은 현행법 해석론을 넘어 향후 입법 설계에 대한 시사점도 가진다.[13]

---

10) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2019다260197 판결. "공법인이 국가로부터 위탁받은 공행정사무를 집행하는 과정에서 공법인의 임직원이나 피용인이 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입힌 경우에는, 공법인은 위탁받은 공행정사무에 관한 행정주체의 지위에서 배상책임을 부담하여야 한다." 이 판결에 대한 판례해설로 이상덕, "대한변호사협회의 변호사등록 지연이 불법행위에 해당하는지의 판단기준", 대법원판례해설 제127호, 법원도서관, 2021.

11) 헌법재판소 2019. 11. 28. 선고 2017헌마759 전원재판부 결정; 헌법재판소 2000. 6. 29. 선고 99헌가9 결정.

12) 대법원 2003. 2. 20. 선고 2001두5347 판결.

13) 특수법인은 공적 기능을 수행하거나 특정 전문영역에서 사회적 영향력을 행사하는 조직인 만큼, 대외적으로 누가 대표자인지, 대표권의 범위가 무엇인지, 그리고 주요 의사결정이 어떤 절차와 권한 구조에 따라 이루어지는지(의사결정의 귀속 구조)가 외부에서 식별 가능해야 한다. 이러한 정보가 공시되지 않은 채 미등기 상태가 지속되면, 이는 단순한 행정적 편의의 문제가 아니라 제3자의 신뢰 기반과 책임 귀속의 연결고리가 약화된 상태, 즉 책임 있는 조직운영의 최소 기반이 결여된 상태로 평가될 수 있다. 이 지점은 특정한 '특수법인'에만 국한된 문제가 아니라, 사회적 영향력이 큰 조직 일반에서 반복될 수 있는 구조적 리스크를 보여준다. 특히 향후 영향력이 큰 운영법인이나 AI 기반 운영조직을 설계하는 경우, 의사결정이 위원회·규정·시스템·자동화된 절차로 분산되면서 "결정은 이루어지는데 누가 최종적으로 대외적 대표권을 가지고 책임을 지는지"가 외부에서 더 불투명해질 가능성이 있다. 따라서 지금의 미등기 문제는, 장래에도 공시·대표권·책임 귀속을 명확히 설계하지 않으면 동일한 종류의 신뢰·책임 문제가 더 큰 규모로 재현될

본 논문은 이 법리상의 공백을 메우는 것을 목적으로 한다. 본 논문은 특정 사건의 결론 자체에 대한 옹호 또는 비판을 목표로 하기보다는, 그 사건을 계기로 드러난 특수법인 설립등기 규율 구조를 분석하고 설립등기의 법적 근거와 효력이 체계적으로 정리되어 있지 않은 상태를 보완하는 이론적 틀을 제시하는 데에 초점을 둔다. 분석의 중심 소재는 5개 직능단체법(의료법・변호사법・변리사법・세무사법・법무사법)이되, 공법인의 이중적 법적 성질에 관한 이론적 기반을 함께 검토함으로써 분석의 사정범위를 특수법인 일반으로 열어둔다. 구체적으로는 대한의사협회와 대한변리사회처럼 민법 사단법인 규정의 준용이 명시된 단체와, 대한변호사협회・지방변호사회・한국세무사회・대한법무사협회 및 지방법무사회처럼 법인격만 부여되고 일반법 준용이 명문으로 드러나지 않는 단체를 비교한다. 변호사법상 법무법인과 법무법인(유한)은 회사형 특수법인에 관한 보조 사례로만 다룬다.[14] 연구방법으로는 문헌연구, 독일・미국・일본과의 비교법적 검토, 판례 및 등기선례 분석, 실정법 분석을 수행한다.

종래 법인의 기본권에 관한 연구는 주로 사법인의 기본권 주체성 및 인정 범위에 초점을 맞춰 전개되었고, 법인설립등기제도에 관한 연구 역시 민법상 비영리법인이나 상법상 회사를 대상으로 하고 있으며, 특수법인의 등기제도에 대해서는 단편적으로만 언급되고 있다. 법인격 개념의 형성과 발전에 관한 최근의 연구는 법인격의 상대화 문제를 제기하고 있으나, 이를 특수법인의 등기제도와 연결하는 시도는 이루어지지 않았다.[15] 특수법인 설립시 종전 단체의 권리・의무 승계에 관한 연구[16]는

수 있음을 시사한다. 이하 대법원 2008. 6. 12. 선고 2008다13050 판결 참조.

14) 의료법 제28조 제2항, 제4항; 변리사법 제9조 제1항, 제3항; 변호사법 제58조 제1항, 제64조 제2항, 제78조 제2항; 세무사법 제18조; 법무사법 제52조 제2항, 제62조 제2항.

15) 김승환은 성질설에 따라 법인의 기본권능력을 정리하였고, 이상학은 공법인과 사법인의 기본권능력 범위를 구별하면서 공법인의 기본권능력 인정에 신중한 입장을 취한 바 있다. 나아가 조소영은 주식회사의 표현의 자유 보장을 중심으로 법인의

특별법 부칙의 입법기술적 불비를 지적하고 있으나, 등기 근거와 효력의 문제는 다루지 않았다.

특수법인의 설립등기에 관한 법리 공백은 부동산거래 영역에서 특히 심각한 결과를 초래한다. 특수법인이 부동산을 취득・처분하거나 근저당권을 설정하고 임대차 계약을 체결하는 과정에서, 대표자와 대표권 제한을 등기부를 통하여 확인할 수 없으면 거래 상대방은 정관・회의록 등 내부자료에 의존할 수밖에 없고, 이는 고액 처분행위에 대한 사전통제 장치가 사실상 작동하지 못하는 결과를 가져온다. 물권변동의 전제가 되는 등기실무에서도 대표자・대표권 확인에 소요되는 비용과 시간은 증가하고, 대표권 흠결을 둘러싼 분쟁 비용은 상대방과 사회 전체로 외부화된다. 이러한 점에서 특수법인 설립등기의 법적 근거와 효력을 부동산거래 안전과 연결하여 구조적으로 재검토하는 작업은 부동산법학의 과제로도 의의를 가진다.

이하에서는 먼저 법인설립등기의 일반이론과 특수법인의 이중적 법적 성질을 확인한 뒤, 5개 직능단체법의 준용 규정 유무와 등기실무의 문제 상황을 검토한다. 이어 비송사건절차법・등기규칙・선례변경을 중심으로 준용규정 없는 특수법인의 설립등기 근거를 도출하고, 그 등기

기본권 주체성 문제를 다룬다. 등기제도에 관하여 송호영은 비영리법인 및 회사의 등기・등록제도 정비를 중심으로 논의를 전개하거나 법인격의 상대화 문제를 제기하지만, 두 논문 모두 특수법인의 설립등기 근거와 효력을 별도의 대상으로 삼지는 않는다. 이하 김승환, "법인의 기본권 주체성", 고시계 제47권 제2호, 고시계사, 2002, 4쪽; 이상학, "법인의 기본권능력에 관한 일고찰", 공법학연구 제20권 제1호, 한국비교공법학회, 2019, 343쪽; 조소영, "주식회사와 정치적 표현의 자유 - 기본권 주체성 여부를 중심으로 -", 헌법재판연구 제7권 제1호, 헌법재판연구원, 2020, 3쪽; 송호영, "법인설립에 있어서 등기・등록제도의 개선방안 연구", 비교사법 제16권 제4호, 한국사법학회, 2009, 1쪽; 송호영, "법인격의 형성과 발전 - 새로운 법인격 개념의 정립은 필요한가? -", 재산법연구 제38권 제2호, 한국재산법학회, 2021, 23쪽.

16) 추선희/김제완, "특수법인 설립시 종전 단체의 권리・의무 승계의 범위 - '아시아문화원' 판결에 대한 비판적 검토 -", 법조 제68권 제2호, 사단법인 법조협회, 2019, 431쪽.

가 사법상 거래영역에서 대표권 공시와 대항요건으로 기능하는 구조를 분석한다. 마지막으로 등기 거부 또는 직권말소에 대한 불복 경로와 입법적 개선 방향을 제시한다.

Ⅱ. 법인설립등기의 일반이론과 특수법인의 법적 성질

1. 법인격의 형성과 법인설립등기

1.1 법인법정주의와 법인격의 법기술적 성격

민법에서 법인은 자연인과 함께 권리주체로 인정되고 있으며, 현대사회에서 법인이 주도하는 경제 활동의 규모는 자연인의 주도하에 이루어지는 거래행위의 규모와 비교했을 때 그 범위가 상당하다. 법인은 자연인과 달리 그 자체를 목적으로 가지는 존재가 아닌 법기술적 개념(rechtstechnischer Begriff)으로 형성된 것이다.[17] 이러한 점을 바탕으로 하여, 각 나라에서는 '법인제도'의 존재는 인정하고 있으나 단체에 대하여 법인격을 부여하는 방법이나 절차는 서로 다르게 나타난다.

우리 민법은 제31조에서 "법인은 법률의 규정에 의함이 아니면 성립하지 못한다"고 규정하여 법인법정주의를 채택하고 있다. 법인격이란 통설에 의하면 권리와 의무의 귀속주체가 될 수 있는 자격 또는 지위를 의미하며, 법인격을 가진다는 것은 권리의 귀속자로서의 지위뿐만 아니

17) 법인을 '법기술적 개념'으로 파악하는 점과, 국가마다 법인격 부여 방식이 다르다는 비교법적 관찰은 송호영, "법인설립에 있어서 등기·등록제도의 개선방안 연구", 비교사법 제16권 제4호, 한국사법학회, 2009, 7쪽; 권철, "한국 민사법 상의 法人論", 민사법학 제77권, 한국민사법학회, 2016, 290-293쪽을 참조한 것이다. 이들 논문은 법인제도의 개념적 성격과 법인법정주의의 의미, 각국의 법인제도 구성을 포괄적으로 검토한다.

라 의무의 귀속자의 지위를 동시에 가진다는 것이다.[18] 민법상 비영리법인은 설립등기를 함으로써 성립하며(민법 제33조), 대법원은 "법인은 설립행위를 거쳐 설립등기를 함으로써 성립하고 법인격을 취득하며, 설립등기는 다른 등기와 달리 창설적 효력을 가지는" 강행규정이라고 판시하여 설립등기의 창설적 성격을 명확히 하고 있다.

1.2 설립등기의 창설적 효력과 대항력

설립등기는 법인의 존재를 외부에 공시하는 기능과 함께, 사법상 거래관계에서 실체법적 효력을 가진다. 민법 제54조 제1항은 설립등기 이외의 본절의 등기사항은 등기 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다고 규정하고 있고,[19] 민법 제60조는 이사의 대표권 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다고 규정하고 있다.[20] 이처럼 설립등기는 단순한 공시 기능을 넘어 대항력을 좌우하는 권리형성적 요건으로 작용한다. 법인설립등기의 효력이 창설적이라는 것은 법인설립을 목적으로 한 단체가 설립 중인 법인에서 설립등기에 의해 비로소 하나의 법인으로 완전한 권리주체성을 인정받게 됨을 의미하는 것이며, 법인등기를 마친 단체에 대해서는 존립의 다툼에 있어서도 보다 강한 보호를 하게 된다.

---

18) 송호영, "법인의 권리능력", 비교사법 제7권 제1호, 한국사법학회, 2000, 103쪽; 대법원 2009. 4. 9. 선고 2007두26629 판결; 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008두4534 판결.

19) 대표권 제한의 등기능력에 관하여는 구별설과 비구별설의 대립이 있다. 구별설은 일정한 법률행위에 대한 사원총회・이사회 동의 요건 등을 이사의 내부적 업무집행 지침에 불과한 것으로 보아 등기능력을 부정하는 반면, 비구별설은 절차적 제한・방식상의 제한・범위의 제한을 모두 포괄적 대표권 제한에 포함시켜 등기능력을 인정한다. 판례는 비구별설의 입장을 확고히 취하고 있다. 이하 남효순, "민법상 이사의 대표권제한", 135-137쪽.

20) 설립등기의 창설적 효력과 '설립 중의 법인' 단계에서 설립등기를 통해 완전한 권리주체성을 취득한다는 점에 관하여는 송호영, "법인설립에 있어서 등기・등록 제도의 개선방안 연구", 5-22쪽.

등기제도는 본질적으로 단순한 행정적 공시를 넘어, 거래 당사자의 실체적 권리를 보호하는 강력한 실체법적 효력을 지닌다. 특히 사법상 법인이 제3자와 계약을 체결함에 있어 대표권 제한은 정관에 기재되어 있더라도 등기되지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다. 이 점에서 법인등기는 단순한 정보 제공을 넘어, 대표권 제한과 등기사항 일반이 외부 거래관계에서 대항력을 갖기 위한 제도적 매개로 기능한다.[21] 결국 일반 법인의 설립등기와 변경등기는 존재 공시, 대표권 공시, 대표권 제한의 대항력 확보라는 다층적 기능을 결합한 제도이다.[22]

1.3 법인격의 상대화 논의와 특수법인의 위치

한편, 법인격에 대한 통설적 설명은 오늘날 적지 않은 도전을 받고 있다. 비법인사단이나 조합처럼 법인격은 없으면서도 부분적 권리능력을 가지는 경우에는, 법인격은 없지만 문제된 법률관계에 한해서 권리주체성(Rechtssubjektivität)이 인정되는 구조가 나타난다. 이러한 법인격의 상대화 논의는 특수법인의 등기 문제에 중요한 시사점을 제공한다.[23]

---

21) 등기제도가 단순 공시수단을 넘어 실체법적 권리 보호 기능을 가진다는 점과 대표권 제한의 미등기 시 대항력 상실이라는 구조에 관하여는 박기주, “등기청구권의 비교법적 의미”, 법학논고 제40집, 경북대학교 법학연구원, 2012, 405-422쪽; 고상현, 앞의 논문, 3-17쪽 및 22-24쪽.

22) 요컨대 민법상 비영리법인에서 설립등기는 민법 제33조에 따라 법인격 발생의 성립요건으로 기능하는 반면 설립등기 후에 발생하는 변경등기나 대표권 제한 등기는 법인격 자체를 새로 발생시키는 것이 아니라, 이미 존재하는 법인의 등기사항을 외부에 공시하고 제3자에 대한 대항요건을 갖추게 하는 기능을 한다. 따라서 설립등기의 창설적 효력과 그 밖의 등기의 대항요건적 효력을 혼동해서는 안 되며, 특수법인 설립등기의 효력도 이 구별을 전제로 검토되어야 한다.

23) 법인격의 상대화와 권리주체성・권리능력의 분리 가능성에 관한 논의는 송호영, “법인격의 형성과 발전 - 새로운 법인격 개념의 정립은 필요한가? -”, 재산법연구 제38권 제2호, 한국재산법학회, 2021, 25-28쪽을 참조하였다. 다만 본문에서 말하는 ‘불완전한 법인격’은 송호영이 말하는 권리능력의 상대화(법인격 자체의 유무 판단 구조)와 달리, 이미 법인격을 부여받은 특수법인이 등기제도의 부재로 인해 사법상

특수법인은 법률에 의해 법인격을 부여받았으므로 형식적으로는 완전한 권리주체이다. 그러나 법인등기부가 존재하지 않는 특수법인은 대표권의 공시, 대표권 제한의 대항력 확보, 등기사항의 제3자 대항이라는 사법상 거래질서의 핵심 기능이 작동하지 않는 상태에 놓인다. 본 논문에서 말하는 '불완전한 법인격'은 법인격 자체가 결여되었다는 규범개념이 아니다. 이는 설립근거법에 의해 법인격은 이미 부여되었으나, 등기부 부재로 인해 대표권 공시와 대표권 제한의 대항요건이라는 거래법적 기능이 충분히 작동하지 못하는 상태를 설명하기 위한 서술적 작업개념이다. 이는 법인격 자체의 유무가 상대적으로 판단되는 구조를 분석한 선행연구의 '권리능력의 상대화' 논의와는 관점이 다르다.

1.4 비교법적 개관: 대륙법계와 영미법계의 차이

대륙법계 국가에서는 법인설립을 위해 법인등기를 요구하지만, 영미법계 국가에서는 법인등기제도가 존재하지 않는다. 다만 미국에서도 각 주의 Secretary of State에 설립서류를 제출하고 등록(filing)하는 절차를 통해 법인격을 취득하며, Certificate of Good Standing을 통해 법인의 존재와 적법성을 외부에 공시하는 기능적 등가물을 갖추고 있다.[24] 이는 법인격 부여 방식이 다르더라도 사법상 거래에 참여하는 법인에게 외부적 공시수단이 요구된다는 점이 법계(法系)를 초월한 공통 원칙임을 보여준다. 한편 법인설립등기를 요구하는 대륙법계 내에서도 법인 유형에 따라 등기·등록의 의미와 효력은 상이하게 나타나며, 이 점은 Ⅱ.3.2의 독일 공법인과의 비교에서 구체적으로 확인된다.[25]

거래질서에서 그 기능을 완전하게 수행하지 못하는 상태를 지칭하는 기술적 용어에 불과하다.

24) 미국의 법인등록 절차와 Certificate of Good Standing의 기능에 관하여는 송호영, "법인설립에 있어서 등기·등록제도의 개선방안 연구", 3-5쪽.

25) 법인이 '사회적 실재'로서 사법상 거래의 주체로 자리 잡았다는 진단과, 비영리·공

1.5 주무관청의 인·허가와 법인설립등기의 구조

민법상 법인은 설립자의 설립행위(정관 작성·기관 구성) → 주무관청의 인·허가 → 설립등기라는 단계적 과정을 거쳐 성립한다. 이 구조에서 설립등기는 법인격의 완성을 확정하는 창설적 효력을 가진다(민법 제33조). 그러나 특수법인은 법률 또는 행정법령에 근거하여 이러한 단계적 과정을 거치지 않고 직접 성립하는 경우가 대부분이다. 이처럼 비단계적으로 생성되는 법인에서는 설립등기가 법인격 창설의 기능을 수행하지 않으며, 이 구조적 차이가 특수법인의 설립등기에 관한 법적 근거와 효력을 둘러싼 해석론적 공백을 야기한다. 이 공백의 구체적 양상과 그 해소 방안은 Ⅲ장 이하에서 검토한다.

2. 특수법인의 개념과 유형

특수법인이란 민법 및 상법 외의 법령에 의하여 설립된 법인을 말하며, 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제1조가 이 용어를 정의하고 있다.[26] 법인 중에서 국가정책상 필요나 공공의 이익을 달성하기 위해 민법 또는 상법 외의 특별법에 따라 설립되는 법인을 가장 넓은 의미에서의 '특수법인'이라 칭하며, 법률상 명칭은 '공사', '공단', '연구원', '협회', '공제회' 등으로 다양하게 규정되고 있다. 특수법인의 대체적인 특징으로는 ⅰ) 민법과 상법의 규정만으로는 설립하려는 법인의 형태나 기능, 그에 대한 감독 등에 관한 입법 목적을 충분히 달성할 수 없어 다른 특별법에 따라 설립된다는 점, ⅱ) 국가에 의하여 설립되는 관계로 국가의 재정적 지원과 함께 국가의 감독을 받는다는 점, ⅲ) 설립 목적을 달성하기 위해

익법인에 대한 국가 후견 통제의 축소 및 자율성·거래안전의 조화 필요성에 관하여는 권철, 앞의 논문, 292-298쪽; 송호영, "한국에서의 비영리법인 및 공익법인에 관한 법정책적 개선방안", 법학논총 제43호, 숭실대학교 법학연구소, 2019, 273-294쪽.

26) 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제1조.

공적 사무의 수행과 함께 제한된 범위에서 공권력을 행사하고 법인의 존속이 국가에 의하여 결정된다는 점 등을 들 수 있다.

특수법인 중에서도 법률에 의해 직접 설립되고, 구성원의 강제가입이 규정되며, 직업윤리 확립・보수교육・자율규제 등 공적 기능을 수행하는 것을 본 논문에서는 '직능단체형 특수법인'이라 칭한다. 이들은 공적 기능을 수행하는 동시에 부동산의 취득・처분, 금융거래, 각종 계약의 체결, 소송의 수행 등 사법상 거래의 주체로서도 활동한다. 그러나 특별법에 의하여 법인격이 직접 부여되는 구조이므로, 민법상 비영리법인의 단계적 설립 과정이 그대로 적용되기 어려우며, 이 구조적 차이가 특수법인 설립등기에 관하여 어떤 법규를 근거로 삼아야 하고, 그 등기가 사법 영역에서 어떤 효력을 가지는지에 관한 법리가 정립되어 있지 않은 상태를 낳는다. 나아가 특수법인 관련 특별법의 입법기술적 불비는 등기 규정의 부재에만 국한되지 않는다. 포괄승계 규정의 범위 불명확, 설립준비 규정의 미비 등 보다 넓은 범위의 구조적 흠결이 지적되어 왔으며,[27] 등기 근거의 공백은 이러한 입법기술적 불비의 한 단면이다.

3. 공법인의 이중적 법적 성질

3.1 대한변호사협회・대한의사협회의 법적 지위

우리나라에서 공법인으로 분류되는 단체는 헌법재판소의 판결을 기준으로 대한변호사협회,[28] 의료보험조합,[29] 농지개량조합,[30] 재개발조

27) 특수법인 설립 전후의 권리・의무 승계 과정에서 특별법 부칙의 포괄승계 규정이 승계 범위를 명확히 제시하지 못한다는 점은 추선희/김제완, 앞의 논문, 432-462쪽 이하에서 자세히 지적된다. 나아가 류철호 법제처 사무관 역시 특수법인 설립 관련 규정이 체계적으로 정비되어 있지 않다는 점을 들어 입법기술의 개선 필요성을 제기한다. 이하 류철호, "특수법인의 설립준비규정에 관한 검토", 월간법제 제2005. 11월호, 법제처, 2005, 66-78쪽.

28) 헌법재판소 2000. 6. 29. 선고 99헌가9 결정.

합,[31] 농업기반공사[32] 등이 있다.

대한변호사협회에 대하여 헌법재판소는 "변호사 등록에 관한 한 공법인으로서 공권력 행사의 주체"로 인정하였고(2017헌마759; 같은 취지로 2021헌마169), 대법원은 "국가로부터 위탁받은 공행정사무에 관한 행정주체의 지위"를 인정하면서 임직원이 "실질적인 의미에서 공무를 수행한 사람으로서 국가배상법 제2조에서 정한 공무원에 해당한다"고까지 판시하였다.[33] 서울고등법원도 대한변호사협회의 공법인적 지위를 재확인한 바 있다.[34] 그러나 변호사법 제78조 제2항은 "대한변호사협회는 법인으로 한다"고만 규정할 뿐, 민법 또는 상법의 준용에 관한 규정을 두고 있지 않다. 동시에 대한변호사협회는 400억 원 이상의 자산을 운용하고 다양한 사법상 행위를 수행하고 있다.[35] 대한의사협회는 의료법 제28조에 근거하여 설립되는 법정단체로서, 의료법 제28조 제4항에 의해 민법 중 사단법인에 관한 규정이 준용되어 사법상 독립된 권리주체로 기능한다. 대법원은 대한의사협회를 사업자단체로 보아 사법상 거래관계의 주체임을 인정하였다.[36]

이처럼 대한변호사협회와 대한의사협회는 공법인·행정주체이면서 동시에 사법상 거래의 주체라는 이중적 법적 지위를 가진다. 이러한 이중성은 법인격 취득 방식과 권리능력의 범위를 둘러싼 문제를 야기하

29) 헌법재판소 2000. 6. 29. 선고 99헌마289 결정.

30) 헌법재판소 2000. 11. 30. 선고 99헌마190 결정; 헌법재판소 1991. 3. 11. 선고 90헌마28 결정.

31) 헌법재판소 1997. 4. 24. 선고 96헌가3·96헌바70 결정.

32) 헌법재판소 2001. 4. 26. 선고 2000헌마122 결정.

33) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2019다260197 판결.

34) 서울고등법원 2024. 10. 24. 선고 2023누43763 판결.

35) 법조신문, 박시형, "[판례평석] 대한변호사협회 법인변경등기신청 각하결정에 대한 이의사건", 2025. 2. 26, <https://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=32801>, 검색일: 2026. 3. 11.

36) 대법원 2003. 2. 20. 선고 2001두5347 판결.

며, 설립등기의 법적 성질을 적용 법규의 차이에 따라 분리하여 파악해야 할 근거를 제공한다. 이 기술적 진단은 Ⅴ장에서 제시하는 이원적 효력론의 사실적 전제를 구성한다. 즉 특수법인의 설립등기가 사법상 거래 영역에서 어떤 효력을 가지는지를 논증하기 위해서는, 먼저 미등기 상태에서 법인격이 어떤 기능적 결손을 보이는지를 확인하는 작업이 선행되어야 하며, '불완전한 법인격'이라는 기술은 바로 그 역할을 수행한다.

3.2 독일 공법상 법인과의 비교

독일의 의사협회는 명시적으로 공법상 법인 또는 공법상 단체(Körperschaft des öffentlichen Rechts)로 구성되어 있으며,[37] 이는 공법인의 법적 성질을 가장 전형적으로 보여주는 사례로 평가된다. 독일 각 주(Land)의 의사협회는 법률에 의해 설립되며, 의료인의 직업윤리 확립, 보수교육, 자율적 규제 등 공적 기능을 수행하는 동시에, 구성원의 이익을 대변하는 단체로서 사법상 활동도 수행한다. 독일의 변호사회 역시 국가로부터 규제 및 감독 기능을 위임받은 공법상 단체로 기능하며, 이는 한국의 대한변호사협회가 국가의 고권적 의사에 의해 설립된 공법인으로 평가받는 것과 궤를 같이한다.[38] 한·독 양국의 공법인들은 국가 사무를 위탁받은 공법적 실체임과 동시에 사법상 거래의 주체라는 독자적인 구조적 특성을 공유하고 있다.

독일기본법(Grundgesetz) 제19조 제3항은 "기본권은 그 성질상 법인에게도 적용될 수 있는 한, 국내 법인에게도 적용된다"고 규정하고 있다. 연방헌법재판소(BVerfG)는 공법인의 기본권능력에 대하여 원칙적으로

37) Körperschaft des öffentlichen Rechts는 직역하면 '공법상의 단체' 또는 '공법상 법인'에 가까우며, 민법상 사단법인인 Verein과 구별된다. 따라서 본 논문에서는 Verein과의 개념 혼동을 피하기 위하여 이를 '공법상 법인' 또는 '공법상 단체'로 번역한다.

38) 이상덕, "변호사회의 법적 성질과 소송형식", 30-32쪽.

제한적인 입장을 취하고 있으나,[39] 법질서를 통해 위임된 업무로부터 직접적으로 특정 기본법상으로 보호된 생활영역에 귀속되는 공법상 단체의 기본권능력은 인정하고 있다.[40]

독일에서 공법인의 법인격은 설립행위(Errichtungsakt) 자체에 의해 발생하며, 법인등기부(Handelsregister)나 사단등기부(Vereinsregister)에의 등기가 성립요건으로 요구되지 않는다.[41] 각 주의 의사직업법(Heilberufsgesetz) 또는 변호사법(BRAO)이 해당 협회를 직접 설립하는 구조를 취하고 있으므로, 별도의 등기절차 없이 법인격이 완성된다. 다만 각 주의 행정기관이 관리하는 법인 목록(Körperschaftsverzeichnis)에 기재되는 경우가 있으나, 이는 등기가 아닌 행정적 기록에 해당한다. 그러나 공법인이 사법상 법률관계에 참여하는 경우 — 예컨대 부동산 취득, 계약 체결 등 — 그 법적 지위와 대표권의 외부적 인식 가능성이 문제되며, 공증인의 확인(notarielle Bescheinigung)이나 감독관청의 증명서 등 공시 기능의 대체 수단이 활용된다. 이러한 구조는 공법인에게도 사법 영역에서의 활동을 위한 외부적 공시수단이 불가결하다는 점을 보여주되, 그 수단이 반드시 등기일 필요는 없다는 점에서 우리 법제와의 비교에 유의미한 시사점을 제공한다. 나아가 독일 연방대법원(BGH)

39) 연방헌법재판소법(BVerfGG) 제90조 제1항에 따르면, "누구든지" 공권력에 의해 자신의 기본권 또는 기본권에 준하는 권리가 침해되었다고 주장하며 헌법소원을 제기할 수 있다. 따라서 침해되었다고 주장되는 기본권 또는 기본권에 준하는 권리의 소유자가 될 수 있는 사람은 누구나 소명을 제기할 자격이 있다. 기본법(GG) 제19조 제3항에 따르면, 국내 법인 또한 그 성격상 적용되는 기본권이 침해당하는 한 기본권의 소유자이다. 기본권은 주로 자연인으로서 개인의 자유 영역을 국가권력의 간섭으로부터 보호하는데 목적이 있다. 이러한 맥락에서, 공적 기능을 수행하는 공법상 법인의 기본권 보유 능력은 일반적으로 부인된다. 공공 부문이 소유하거나 통제하는 사법상 법인에도 동일하게 적용된다(BVerfGE 128, 226 참조).

40) 이상학, 앞의 논문, 343-371쪽.

41) 독일의 공법상 사단법인은 Handelsregister(상업등기부)의 등기 대상이 아니며, Vereinsregister(사단등기부) 역시 민법상 사단법인(e.V.)을 위한 것이므로 공법인에는 적용되지 않는다. 이상덕, "변호사회의 법적 성질과 소송형식", 30-32쪽; 송시강, 앞의 논문, 21-23쪽.

은 2001년 판례 변경을 통해, 명시적인 법인격이 없는 민법상 조합(GbR)에 대해서도 실질적인 단체성을 띠는 경우 권리능력과 당사자능력을 전향적으로 인정한 바 있다. 이는 사법 영역에서 활동하는 단체에게는 명목상의 법인격 부여 여부보다, 실체적 권리주체로서 활동할 수 있는 절차적 기반을 보장하는 것이 현대 사법의 확고한 추세임을 보여준다.[42)]

이상의 독일 사례는 공법인이 사법 영역에서 활동하는 경우에도 외부적 공시수단이 기능적으로 요구된다는 점을 확인하는 데 주요한 비교법적 의의를 가진다. 어떤 제도가 그 공시 기능을 담당할 것인지는 각 국가의 법인등기・공증・행정기록 체계에 따라 달라질 수 있으며, 독일의 대체 수단(공증인 확인, 감독관청 증명서 등)은 한국의 법제에 그대로 이식될 수 있는 것은 아니다. 한국법에서는 이미 민법과 상법에 기초한 법인등기제도가 대표권 공시와 대항력 구조를 통일적으로 형성해 왔으므로, 특수법인의 사법상 거래에서도 이 체계가 기능적 기준점이 된다. 이 점이 Ⅳ장 이하에서 전개하는 누적적 등기 근거론의 제도적 배경을 이룬다.

3.3 일본 弁護士法과의 비교

비교법적으로 주목할 것은 한국 변호사법과 같은 해(1949년)에 제정된 일본 弁護士法이다. 일본 弁護士法 제34조는 변호사회(弁護士会)의 설립등기를 성립요건으로 규정하면서 등기사항과 제3자 대항력을 명시하고, 별도의 정령(弁護士会登記令, 1949년 정령 제321호)으로 등기절차

42) 명시적인 법인격이 없는 민법상 조합(GbR)에 대해서도 실질적인 단체성을 기준으로 권리능력과 당사자능력을 인정한 독일 연방대법원의 판례 변경과 그 의미에 관하여는 윤진수, “민법상 조합의 권리능력에 관한 독일의 동향”, 법조 제72권 제1호, 사단법인 법조협회, 2023, 35-57쪽; 류승훈, “민법상 조합에 대한 권리주체성 및 당사자능력의 인정과 관련하여”, 민사소송 제11권 제1호, 한국민사소송법학회, 2007, 101-124쪽.

를 구체화하고 있다. 즉 일본에서는 변호사회가 공적 기능을 수행하는 법정단체임에도 불구하고 설립등기를 성립요건으로 요구함으로써, 사법상 거래질서와의 연결 문제를 입법 단계에서 해결하고 있다. 한국 변호사법에 이에 상응하는 규정이 부재하다는 점은, 변호사회와 같은 직능단체형 특수법인의 설립등기와 사법상 거래질서의 접속을 명시적으로 규율하지 않고 있는 입법적 공백을 드러내는 방증으로 이해될 수 있다. 일본 변호사법 제34조의 등기 효력이 민법 제33조와 동일한 성립요건적 창설인지, 공법적 법인격을 전제로 한 대항요건적 효력인지는 별개의 문제이므로, 본 논문은 이와 같은 효력론을 직접 원용하지 않고, 입법기술상의 차이를 드러내는 자료로서만 참고하는 데에 그친다.[43]

3.4 소결

이상의 논의를 종합하면, 공법인은 그 설립 근거와 기능에 있어 공법적 성격을 가지면서도, 현실적으로는 사법상 거래관계에 적극적으로 참여하는 권리주체로 기능한다는 점에서 이중적 법적 성질을 가지는 법인으로 이해할 수 있다. 이러한 이중성은 설립등기의 법적 성질을 적용 법규의 차이에 따라 분리하여 파악해야 할 근거를 제공한다. 즉 설립근거법이 적용되는 영역에서의 등기 효력과, 민법이 보충적으로 적용되는 사법상 거래 영역에서의 등기 효력은 구별되어야 한다.

43) 일본 弁護士法 제34조 및 弁護士会登記令(1949년 정령 제321호)의 구체적 내용과 입법 경위에 관하여는 다카나카 마사히코(高中 正彦), 변호사법 개설 제5판(『弁護士法概說』 第5版), SANSEIDO, 2020를 참조하였다. 다만 본 논문은 해당 자료를 일본 변호사회 설립등기에 관한 규정의 존재를 확인하는 수준에서만 활용하며, 등기 효력의 정확한 성질에 관한 일본 학설의 상세한 논의는 직접적으로 원용하지 않는다.

4. 설립등기의 효력에 관한 기존 이론과 본 논문의 위치

민법 제33조는 "법인은 설립등기를 함으로써 성립한다"고 규정하여, 민법법인에서 설립등기는 법인격 자체를 발생시키는 성립요건적 효력(이하 '성립요건적 창설')을 가진다. 반면 학설과 실무에서 인정되는 '공시적 효력'은 이미 존재하는 법인의 외형을 외부에 표시하는 기능을 가리킨다.

본 논문이 Ⅴ장에서 제시하는 이원적 효력론은 이 양자와 구별되는 제3의 효력 개념을 도입한다. 특수법인의 설립등기가 사법 영역에서 가지는 효력은, 법인격 자체의 발생이 아니다. 특수법인의 법인격은 이미 설립근거법에 의해 부여되기 때문이다. 따라서 이 경우 등기의 효력은 대표권 공시, 대표권 제한의 대항요건, 등기사항의 제3자 대항이라는 사법상 거래기능을 보충적으로 완성하는 데 있다. 이하에서는 이를 '거래법적 보충효'라 한다. 이는 대표권 제한과 등기사항 일반이 제3자에 대하여 대항력을 갖기 위한 요건을 충족시키는 기능을 포함한다는 점에서, 제한된 의미의 '대항요건적' 기능을 갖는다. 이 개념은 민법 제33조의 '성립요건적 창설'과도, 단순한 '공시적 효력'과도 구별되는 범주로서, 이를 정리하면 다음 <표 Ⅱ-1>과 같다.

〈표 II-1〉 법인 유형에 따른 설립등기의 효력 분류

효력유형	내용	해당 법인 유형	비고
성립요건적 창설	설립등기를 통하여 법인격 자체가 발생	민법상 비영리법인	민법 제33조
공시적 효력	이미 존재하는 법인의 외형과 기본사항을 외부에 표시	법인등기 일반	공시성은 등기제도 전반의 공통 기능
거래법적 보충효	대표권 공시, 대표권 제한의 대항요건, 등기사항의 제3자 대항을 작동시킴	사법상 거래영역에서 활동하는 특수법인	민법 제54조·제60조와 연결

위 표에서 '공시적 효력'은 특수법인에만 고유한 효력을 의미하지

않는다. 공시적 효력은 부동산등기와 법인등기 전반에서 인정되는 등기 제도의 일반적 기능이다. 본 논문이 특수법인 설립등기와 관련하여 별도로 문제 삼는 것은 공시적 효력 자체가 아니라, 설립근거법에 의해 이미 법인격을 취득한 특수법인이 사법상 거래영역에 참여할 때 그 공시가 민법 제54조 및 제60조의 대항요건 구조와 어떻게 연결되는가이다.

Ⅲ. 특수법인 설립등기의 현행 규율과 문제상황

1. 현행 규율 체계와 그 한계

특수법인의 설립등기 공백은 추상적인 법리 문제를 넘어 구체적인 부동산거래에서 위험으로 표출된다. 예컨대 대한변호사협회나 대한의사협회가 회관 건물을 처분하거나 근저당권을 설정하는 경우, 거래상대방은 누구에게 매매대금을 지급하고 누구와 담보계약을 체결하여야 적법한 처분으로 인정될지를 등기부를 통해 확인하기 어렵다. 대표권 제한에 관한 등기가 불가능한 상태에서는 고액의 처분행위에 이사회 결의를 요하는 규정이 있더라도 제3자에 대한 대항력이 확보되지 못하고, 대표자와 대표권의 존부를 둘러싼 분쟁은 부동산등기실무와 소송절차에서 반복적으로 발생한다. 이와 같은 위험은 특수법인 설립등기의 법적 근거와 효력이 구조적으로 정리되지 않은 데서 비롯된다. 특수법인의 등기에 관한 현행 규율은 법률·대법원규칙·등기선례의 세 층위로 구성되어 있다.

1.1 법률 차원: 비송사건절차법 제67조 제1항

법률 차원에서는 비송사건절차법 제67조 제1항이 특수법인에 대한

법인등기 규정의 적용을 열어두고 있다. 법인의 등기사항 등에 관한 특례법(2024. 9. 20. 법률 제20434호로 일부개정, 2025. 1. 31. 시행) 제1조 역시 “법인(특별법에 따라 설립된 법인, 상사법인 및 민법법인을 말한다)”을 적용 대상으로 명시하고 있어, 특수법인이 법인등기 규율의 대상에 포함됨이 법률 차원에서 재확인된다. 또한 민법법인 및 특수법인 등기규칙도 2024. 11. 29.(대법원규칙 제3170호)에 일부 개정되어 2025. 1. 31.부터 시행되고 있다.

이처럼 상위 법률과 최근 입법 동향은 특수법인을 법인등기 규율의 바깥에 두려는 것이 아니다. 오히려 특수법인이 등기의 적용 대상임을 전제하면서도 그 구체적 구조를 명시하지 않은 상태에 머물러 있다.[44]

1.2 대법원규칙 차원: 등기규칙 제5조 · 제6조 제3항

대법원규칙 차원에서는 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제5조가 특별법령이 정하는 사항의 등기를 규정하고 있으며, 제6조 제3항이 특수법인에 대하여 민법 제50조부터 제52조까지, 제85조, 제94조의 규정 및 상업등기규칙의 일부 규정을 성질에 반하지 않는 한 준용한다고 규정하고 있다. 동 규칙은 2021. 9. 30.(대법원규칙 제2998호) 및 2021. 11. 29.(대법원규칙 제3008호) 두 차례 개정되었으나, 제6조 제3항의 민법 준용 목록 자체는 변경되지 않았다.

다만 민법 제49조는 이 준용 목록에 명시적으로 열거되어 있지 않으며, 이 점이 특수법인 설립등기의 **구체적 법적 근거를 둘러싼 해석상 쟁점의 출발점**이 된다.[45]

---

44) 법인의 등기사항 등에 관한 특례법 제1조. 또한 민법법인 및 특수법인 등기규칙도 2024. 11. 29.(대법원규칙 제3170호)에 일부개정되어 2025. 1. 31.부터 시행되고 있다.

45) 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제6조 제3항. 동 규칙은 2021. 9. 30.(대법원규칙 제2998호) 및 2021. 11. 29.(대법원규칙 제3008호) 두 차례 개정되었으나, 제6조 제3항의 민법 준용 목록 자체는 변경되지 않았다.

1.3 등기선례 차원: 종전 제1-436호와 제3387호 선례변경

등기선례 차원에서는 종전의 상업등기선례 제1-436호가 "특별법에 등기사항 규정이 없으면 등기 불가"라는 입장을 취하고 있었다.[46] 그러나 사법등기심의관은 2021년 5월 31일 제3387호를 통해 이를 변경하였다.

1.4 구조적 한계: 가능성과 근거·효력의 괴리

이 규율 체계에는 구조적 한계가 있다. 비송사건절차법·등기규칙·선례변경을 통해 등기의 가능성은 단계적으로 확인되었으나, "등기할 수 있다"는 점을 확인하는 것에 그칠 뿐, 왜 등기할 수 있는지(법적 근거)와 등기하면 어떤 법적 결과가 발생하는지(효력)에 대해서는 기준을 제공하지 못한다. 더 나아가 구체적 등기사항과 심사기준이 법률·규칙·선례에 분산되어 있어 실무상 일관된 처리 기준을 제공하지 못한다. 결국 현행 체계의 문제는 등기 자체가 불가능하다는 것(무규율)이 아니라, 등기의 법적 근거를 도출하는 해석론적 구조와 등기의 효력을 설명하는 실체법적 틀이 모두 정립되어 있지 않다는 의미에서의 이중적 공백에 있다. Ⅳ장은 전자를, Ⅴ장은 후자를 각각 해소하고자 한다.

2. 준용 규정 유무에 따른 개별법의 비교

2.1 준용 규정이 있는 특수법인

의료법 제28조 제4항은 "민법 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다"고 명시하고 있어, 대한의사협회에 대해서는 민법 제33조·제49조·제54조 등으로의 해석론적 경로가 명확하다.[47] 변리사법 제9조 제3항도

46) 상업등기선례 제1-436호의 내용과 그 해석상 영향에 대해서는 김승열, "특수법인의 설립등기에 관한 입법론적 고찰", 월간법제 제2009. 2월호, 법제처, 2009. 1-7쪽.

유사한 구조이다. 변호사법상 법무법인(제58조 제1항, 상법 합명회사 준용), 법무법인(유한)(제58조의17, 상법 유한회사 준용) 역시 준용의 경로가 명시되어 있다.

2.2 준용 규정이 없는 특수법인

변호사법은 대한변호사협회(제78조 제2항)와 지방변호사회(제64조 제2항)에 대하여 "법인으로 한다"고만 규정할 뿐, 민법 또는 상법의 준용에 관한 규정을 두고 있지 않다. 세무사법 제18조 제2항, 법무사법 제62조 제2항・제52조 제2항도 마찬가지이다. 같은 변호사법 안에서도 법무법인에 대해서는 상법 합명회사 준용을 명시하면서, 대한변호사협회・지방변호사회에 대해서는 아무런 준용 규정을 두지 않아 법률 내부의 비일관성이 뚜렷하다.[48]

2.3 입법 누락의 판단: 민법 제1조와 법률 내부의 비일관성

민법 제1조는 "민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다"고 규정하여, 특별법에 규정이 없는 사항에 대한 민법의 보충적 지위를 선언하고 있다. 이러한 비일관성은 단순한 입법정책상의 차이라기보다는, 민법 제1조가 예정하는 일반법

47) 의료법 제28조 제2항, 제4항; 변리사법 제9조 제1항, 제3항; 변호사법 제58조 제1항, 제58조의17, 제58조의31.

48) 세무사법 제18조 제2항; 법무사법 제62조 제2항, 제52조 제2항; 변호사법 제58조 제1항, 제58조의17, 제58조의31, 제64조 제2항, 제78조 제2항. 같은 법체계 내에서 직능단체형 특수법인과 회사형 특수법인 사이의 준용 규정 유무가 상이하게 배치되어 있다는 점과, 특수법인 관련 등기사항 규정방식의 문제에 대하여는 김가나, "특수법인의 몇 가지 등기사항 분석 및 법령규정방식의 문제점", 2018년도 제2회 등기법포럼: 상업・법인등기의 등기사무처리절차상 제기되는 몇 가지 문제점과 개선방안, 한국등기법학회・대한법무사협회 법제연구소, 2018, 59-97쪽.

보충 구조와 법률 내부의 체계 정합성에 비추어 볼 때 입법 누락으로 평가함이 타당하다. 나아가 변호사법의 연혁적 맥락도 '의식적 배제'라는 해석을 지지하지 않는다. 변호사법은 1949년 법률 제63호로 제정되었으나, 현행 민법은 1958년에야 제정되어 1960년 시행되었다. 변호사법 제정 당시에는 준용 대상인 민법 제3장 자체가 존재하지 않았으므로, 민법 사단법인 규정의 준용을 명시하지 않은 것은 배제의 의사가 아니라 시간적 선후관계에 기인하는 것으로 봄이 타당하다. 이후 변호사법이 수차 개정되면서도 준용 규정이 추가되지 않은 것은, 이 입법적 공백이 시정되지 않은 채 존속한 것이다.[49] 변호사법은 1949년 법률 제63호로 제정된 이래 2024년까지 수차 개정되었으나, 대한변호사협회에 대한 민법 사단법인 준용 규정은 추가되지 않았다.[50]

2.4 비교법적 검토: 일본 弁護士法

한국 변호사법과 같은 해(1949년)에 제정된 일본 弁護士法은 제34조에서 변호사회의 설립등기를 성립요건으로 규정하면서 등기사항과 제3

49) '입법 누락'을 엄격한 의미의 입법부작위 위헌과 구별하여, 동일 유형의 단체에 대한 규율이 법률 간·법률 내부에서 비일관적으로 배치된 상태를 해석상 비일관적으로 평가하는 의미에서 사용하는 점에 관하여는, 비법인사단 규율상의 공백을 지적하는 이혜진, "판례에 나타난 비법인사단의 유형 및 규율에 관한 입법론", 동아법학 제71호, 동아대학교 법학연구소, 2016, 29-56쪽.

50) 다만 제정 시기의 선후관계만으로 준용 규정의 부재를 곧바로 입법 누락으로 단정할 수는 없다. 예컨대 구 국민의료법 역시 민법 제정 이전인 1951년에 제정되었으나, 1962. 3. 20. 전부개정 당시 의료법 제58조 제4항에서 민법 중 사단법인에 관한 규정의 준용을 명시하였다. 이는 민법 제정 이전에 만들어진 직능단체법이라 하더라도, 이후 입법자가 준용 규정을 보완할 수 있었음을 보여준다. 따라서 변호사법상 준용 규정의 부재는 단순한 시간적 선후관계만이 아니라, 동일 유형의 직능단체법 사이에서 보완 여부가 달리 나타난 입법기술상의 비일관성으로 파악하는 것이 타당하다. 나아가 변호사회의 공법인적 성격이 민법 준용을 배제하는 근거가 된다는 반론이 가능하나, 의료법상 대한의사협회도 공법인적 성격을 가지면서 준용 규정을 두고 있는 점에 비추어 이 반론은 성립하기 어렵다.

자 대항력을 명시하고 있다. 한국 변호사법에 이에 상응하는 규정이 부재한 것은 입법 누락이라는 판단을 더욱 뒷받침한다.

2.5 소결

이상의 내용을 정리하면 다음 <표 Ⅲ-1>과 같다.

〈표 Ⅲ-1〉 5개 직능단체법상의 민법 준용 규정 및 등기부 존재 여부 (2024. 12. 1. 기준)

법률	법인 유형	민법/상법 준용 규정	설립등기 규정	법인등기부 존재 여부※
의료법	대한의사협회	민법상 사단법인 규정 준용 (제28조 제4항)	명문 규정 없음 (민법 보충 적용)	존재
변리사법	대한변리사회	민법상 사단법인 규정 준용 (제9조 제3항)	명문 규정 없음 (민법 보충 적용)	존재
변호사법	대한변호사협회·지방변호사회	"법인으로 한다"만 규정 (제78조 제2항, 제64조 제2항)	설립등기 규정 없음	존재·부재
세무사법	한국세무사회	"법인으로 한다"만 규정 (제18조 제2항)	설립등기 규정 없음	부재
법무사법	대한법무사협회·지방법무사회	"법인으로 한다"만 규정 (제62조 제2항, 제52조 제2항)	설립등기 규정 없음	부재

※ 등기부 존재 여부는 2024. 12. 1. 기준 대법원 인터넷등기소 법인등기부 열람 결과에 의한다.

3. 기능별 승인의 한계와 실무상 장애

3.1 현행법상 기능별 부분적 권리주체성 승인

현행법은 미등기 단체에 대하여 기능별로 부분적 권리주체성을 승인해 왔다. 민사소송법 제52조는 비법인사단의 당사자능력을, 부동산등기법 제26조는 비법인사단 명의의 부동산등기를, 국세기본법 제13조 제1항은 미등기 단체의 법인 의제를 각각 인정한다.[51] 그러나 이러한 기능

51) 민사소송법 제52조; 부동산등기법 제26조; 국세기본법 제13조 제1항; 대법원 2018.

별 승인은 통일적 공시기반을 대체하지 못한다. 비법인사단의 경우에도 부동산등기법과 예규를 통하여 대표자 등기를 통한 공시・대항 체계가 부분적으로나마 마련되어 있는 반면, 법률에 의해 법인격까지 부여받은 특수법인은 설립등기 자체에 관한 명문의 근거가 부재한 탓에 동일한 부동산거래에서 오히려 더 불리한 대외적 지위에 놓이게 된다. 이는 권리능력의 강도와 거래보호 장치가 역전되는 구조로서, 법체계상 정합성 측면에서도 수긍하기 어렵다.

3.2 기능별 승인과 특수법인의 형평성

법인격조차 없는 비법인사단에도 기능별 권리가 부분적으로 인정되는데, 법률에 의해 법인격을 부여받은 특수법인이 법인등기부 부존재로 인해 대표권 확인・대항력 확보・신용확인에 있어서 비법인사단보다 오히려 불리한 지위에 놓이는 것은 법체계의 내적 부정합이다. 이에 대하여는 비법인사단에 대한 기능별 승인이 법인격의 부재를 보완하기 위한 예외적 제도일 뿐이며, 등기부의 존재를 전제로 하지 않는다는 점에서 특수법인과 단순비교하기 어렵다는 반론이 가능하다. 그러나 이 논증에서 비교의 기준은 등기부의 유무 자체가 아니라, 대표권과 그 제한을 외부에 공시하여 제3자 대항력을 확보해야 할 기능적 필요에 있다. 비법인사단이든 법인격을 부여받은 특수법인이든, 사법상 거래관계에 참여하는 단체라면 이 기능적 필요는 본질적으로 동일하다.

그러므로 법인격을 가진 특수법인이 비법인사단보다 오히려 열악한 공시 기반을 가지는 현상은, 이른바 *a fortiori* 방식의 형평 논증에 비추어 보더라도 법체계 내부의 가치적 부정합으로 평가되어야 한다.[52] Ⅱ.1.3

8. 1. 선고 2018다227865 판결.

52) 설립등기 없는 사단・재단에 대한 기능별 권리주체성 인정과 그 한계에 관하여는 남효순, 「설립등기 없는 사단・재단」의 법적 규율, 법무부, 2014, 1-35쪽.

에서 살펴본 법인격의 상대화 논의에 비추어 보면, 이 상태는 법인격은 있으되 그 법인격이 사법상 거래질서에서 완전하게 기능하지 못하는 구조적 결함에 해당한다.

3.3 국세기본법 제13조의 의무·권리 비대칭

국가가 법인격조차 없는 미등기 단체에 대해서도 국세기본법 제13조에 의해 세법상 법인으로 의제하여 납세의무를 부과하는 구조가 존재한다. 이미 법인격을 부여받은 특수법인의 등기를 거부하는 것은, 의무 부과에 상응하는 권리 기반이 결여된 것으로서 형평의 관점에서도 문제가 있다.

3.4 실무상 장애의 구체적 양상

실무상 장애의 핵심은 세 가지이다.

첫째, 법인등기부가 없어 거래 상대방이 대표자와 대표권 범위를 객관적으로 확인할 수 없다. 이 문제는 소송 과정에서도 현실화된다. 비법인사단(종중) 관련 사건에서 법원은 당사자능력 및 대표권을 직권조사 사항으로 보면서도, 외부 공시가 약하면 실체·대표권 증명 부담이 가중되어 소 각하에 이를 수 있음을 보여준 바 있으며,[53] 특수법인의 경우에도 미등기 상태에서는 동일한 절차적 리스크가 발생한다.

둘째, 대표권 제한을 등기할 수단이 없어 민법 제60조에 의한 대항력 확보가 원천적으로 차단된다.

셋째, 금융기관의 표준적 신용확인 절차에 부합하지 못한다. 금융실명법 체계에서 법인의 실지명의 확인은 시행령상 원칙적으로 사업자등

53) 의정부지방법원 2020. 5. 21. 선고 2019가합55606 판결; 서울고등법원 2012. 8. 1. 선고 2011나65695 판결; 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다308208 판결 참조.

록증・납세번호 문서로 하도록 되어 있으나, 금융기관은 특정금융거래정보법상 고객확인의무(AML)에 따라 법인 고객의 대표자 정보 및 실제 소유자를 확인해야 하며, 이를 위해 실무상 등기사항증명서가 표준 확인 서류로 정착되어 있다.[54] 법인등기부가 부존재하는 특수법인은 이 실무적 확인 경로에 구조적으로 접근할 수 없어, 금융거래의 개시 단계에서부터 장애에 직면하게 된다.

예컨대 지방변호사회가 부동산을 취득하면서 회장이 정관에 의해 5억 원 이상의 거래에 총회 의결을 요하는 대표권 제한을 받고 있다고 하자. 법인등기부가 존재하면 이 제한이 등기되어 제3자에게 대항할 수 있으나, 등기부가 없으면 이 대항력이 원천적으로 작동하지 않는다. 나아가 법인등기부가 폐쇄되면 사업자등록증이 말소되어 세금계산서 발행이 불가능해지고, 법인인감증명서 발급이 중단된다.[55] 이 경우 부동산 거래의 상대방이 부동산등기부를 열람하더라도 법인등기부가 부존재하는 이상 대표권 제한의 존재를 확인할 수 없으며, 민법 제60조에 의한 보호를 받을 수도 없다. 결국 부동산등기제도가 전제하는 법인의 대표권 공시 기능이 법인등기부의 부재로 인해 구조적으로 무력화되는 것이다.

요컨대 현행 규율 체계는 비송사건절차법 제67조, 민법법인 및 특수법인 등기규칙, 사법등기심의관 선례를 통하여 특수법인에 대한 설립등

54) 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령 제10조의4(고객의 신원에 관한 사항), 제10조의5(실제 소유자에 대한 확인); 금융실명거래및비밀보장에관한법률시행령 제4조의2(실명거래의 확인 등) 참조.

55) 법인등기부 폐쇄 시 사업자등록 말소, 세금계산서 발행 불가, 법인인감증명서 발급 중단 등 실무상 장애에 관하여는 법조신문, 박시형, "[판례평석] 대한변호사협회 법인변경등기신청 각하결정에 대한 이의사건", 2025. 2. 26, <https://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=32801>, 검색일: 2026. 3. 11.에서 "단체의 회칙이나 정관은 외부에서는 접근할 수 없기에 … 법인등기부가 없다면 거래상대방 등이 단체의 대표자가 누구인지 대표권 제한사항이 있는지 등을 온전히 확인할 방법이 없다"고 지적하고 있다.

기가 “가능하다”는 점은 확인하고 있다. 그러나 그 등기가 어떠한 조문 구조에 의해 “근거” 지워지는지, 나아가 민법 제54조・제60조에 연결되는 “효력”이 무엇인지에 관하여는 체계적 설명을 제공하지 못하고 있다. 이로 인해 특수법인 설립등기는 등기관의 재량적 허용에 불과한 것인지, 아니면 부동산거래에서의 대표권 공시・대항력 확보를 위해 법질서가 요구하는 필수적 절차인지에 대한 판단이 불명확한 상태로 남아 있다. 이러한 구조적 공백을 메우는 것이 다음 장에서 제시하는 누적적 등기근거론과 이원적 효력론의 과제이다.

Ⅳ. 특수법인 설립등기의 법적 근거

준용규정 없는 특수법인의 설립등기 문제는 단순한 단체 내부의 절차 문제에 그치지 않는다. 설립등기를 부정하면 대표권 공시와 대표권 제한의 대항이라는 거래보호 장치가 구조적으로 작동하지 못하게 되고, 특히 특수법인이 회관 건물과 같은 부동산을 매도하거나 근저당권을 설정하는 고액 거래에서는 위험과 비용이 제3자와 사회 전체로 전가된다. 이 문제는 단체법・공법의 정합성 문제를 넘어, 부동산등기제도의 공시・대항 구조와 직결되는 거래안전의 문제로 재구성되어야 한다. 이러한 관점에서 준용규정 없는 특수법인의 설립등기가 왜 가능한지에 관한 법적 근거를 실정법 질서 안에서 구조적으로 도출하는 작업이 필요하다. 이하에서 제시하는 누적적 등기근거론은 등기의 법적 효력에 관한 ‘위계’를 설정하려는 것이 아니라, 해석상 논거의 기능을 구분하려는 것이다. 제1층은 비송사건절차법・등기규칙・사법등기심의관 선례에 근거한 실정법적 근거로서 설립등기 가능성을 직접 뒷받침한다. 제2층은 민법의 일반법적 지위와 개별 직능단체법 사이의 비일관성을 통해 그 해석의 체계적 정합성을 보강한다. 제3층은 거래안전과 책임배분의 관

점에서 그러한 해석이 필요한 실질적 이유를 제시한다. 따라서 이 세 층위는 서로 경쟁하는 독립 근거가 아니라, 실정법적 근거를 중심으로 체계적·실질적 논거가 누적적으로 보강되는 구조이다.

1. 준용규정이 없는 경우: 누적적 등기 근거론

설립근거법이 민법 또는 상법의 준용을 명시하고 있는 경우, 등기의 법적 근거는 설립근거법과 준용 일반법의 중첩적 구조에 의해 도출된다.[56] 이 경우 등기 근거를 도출하는 데 특별한 해석론적 어려움이 없다.

문제는 "법인으로 한다"는 규정만 있고 준용 규정이 없는 특수법인이다. 본 논문은 등기의 법적 근거를 실정법적 근거 → 체계적 근거 → 실질적 근거의 위계 구조로 제시한다. 이 세 층위의 논거는 각각 독립된 법적 근거를 경쟁적으로 제시하려는 것이 아니다. 해석론적으로 등기 근거를 도출하는 핵심 기반은 비송사건절차법·등기규칙·선례에 의한 제1층의 실정법적 구조에 있으며, 제2층(체계적 근거)과 제3층(실질적 근거)은 그 결론의 정합성과 법정책적 타당성을 서로 다른 차원에서 누적적으로 강화하는 역할을 한다. 이러한 구조는 법해석론에서 통상 사용되는 중첩적 논거 적층 방식에 해당한다. 이 누적적 배치는 각 근거의 논리적 독립성과 논증력의 차이를 반영한 것이다.

1.1 제1층: 실정법적 근거(법률·규칙)

첫째, 비송사건절차법 제67조 제1항은 법인의 등기에 관한 규정이 특수법인에도 적용됨을 법률 차원에서 열어둔다. 단서가 예외로 두는 것은 "그 법령에 특별한 규정이 있거나 성질상 허용되지 아니하는 경우"

56) 의료법 제28조 제2항, 제4항; 변리사법 제9조 제1항, 제3항; 변호사법 제58조 제1항, 제58조의17, 제58조의31; 민법 제33조, 제49조, 제54조, 제60조. 일반법·특별법 관계에서 민법의 보충적 지위와 법인론의 구조에 관하여는 권철, 앞의 논문, 289-299쪽.

뿐이다. 변호사법 등이 등기에 관하여 아무런 규정도 두지 않은 것은 등기를 배제하는 '특별한 규정'이 아니므로, 비송사건절차법 제67조 제1항 본문이 적용된다.

둘째, 등기규칙 제6조 제3항은 특수법인의 등기에 관하여 민법 관련 규정을 성질에 반하지 않는 한 준용한다. 제49조가 명시적으로 열거되어 있지는 않으나, 제3387호는 등기규칙의 등기사항 법정주의가 "등기사항을 개별 법령에 명시된 것으로만 제한하는 의미는 아니다"라고 해석하면서 제49조의 적용을 긍정하였다. 이 해석은 비송사건절차법 제67조 제1항이 특수법인에 대한 법인등기 규정의 적용을 법률 차원에서 열어두고 있다는 점에 의해 상위 법률로부터도 뒷받침된다.[57] 이 제1층의 실정법적 근거만으로도 종전의 '준용 규정이 없으므로 등기 불가'라는 해석은 이미 지지될 수 없다. 이와 같이 비송사건절차법과 등기규칙, 선례에 의해 특수법인에 대한 설립등기 가능성이 실정법 질서 안에서 인정되면, 부동산 처분행위에서 대표자와 대표권 제한을 등기부를 통해 확인할 수 있는 최소한의 제도적 접점이 비로소 마련된다.

1.2 제2층: 체계적 근거(일반법적 지위 · 입법 연혁)

셋째, 민법 제1조는 특별법에 규정이 없는 사항에 대한 민법의 보충적 지위를 선언한다. 이 근거는 독자적으로 특수법인의 등기 근거를 도출하기보다는, 제1층의 실정법적 근거와 결합하여 체계적 정합성을 보강하는 기능을 수행한다. 즉 비송사건절차법이 특수법인에 대한 등기 규정의 적용을 열어두고, 등기규칙이 보충 준용의 틀을 마련한 위에서, 민법 제1조가 구체적 흠결을 메우는 일반 원칙으로 작용하는 것이다. 넷째,

57) 비송사건절차법 제67조 제1항; 민법법인 및 특수법인 등기규칙 제5조, 제6조 제3항; 사법등기심의관 2021. 5. 31. 제3387호(상업등기선례 제202105-3호, 2021. 7. 20. 제정). 종전 상업등기선례 제1-436호가 "특별법에 등기사항 규정이 없으면 등기 불가"라는 입장을 취하였던 점과 그 한계에 관하여는 김승열, 앞의 논문, 7-12쪽.

Ⅲ.2에서 살펴본 바와 같이, 5개 직능단체법의 비교는 준용 규정의 부재가 입법 누락에 해당함을 귀납적으로 확인하였다. 이 진단은 그 자체로 등기 근거를 독자적으로 도출하는 것은 아니나, 제1층의 실정법적 근거가 지향하는 해석의 방향이 체계적으로 정당한 것임을 뒷받침한다.

동일 유형의 특수법인 사이에서 준용 규정 유무에 따라 설립등기 가능성이 우연적으로 갈리는 상태는, 부동산거래에서 대표권 공시의 작동 여부를 일관되게 보장하지 못하게 하여 공시제도의 기능적 정합성을 훼손할 수 있다.

1.3 제3층: 실질적 근거(법정책적 요청)

다섯째, 사법상 거래의 안전과 법적 안정성의 확보는 등기 근거를 인정해야 할 법정책적 이유를 제공한다. 특수법인은 일반 사법인과 달리 법률에 의해 존립이 보장되고, 구성원의 강제가입이 규정되며, 상당한 규모의 자산을 운용하는 경우가 많다. 이러한 단체가 사법상 거래에 참여할 때, 거래상대방은 통상의 사법인 이상으로 그 법적 존재와 대표권 구조를 신뢰할 유인을 가진다. 이 신뢰가 등기부에 의해 뒷받침되지 않으면, 거래안전에 대한 위협은 일반 법인의 경우보다 오히려 심각해질 수 있다.

이와 함께 Ⅱ.3에서 확인한 공법인의 이중적 법적 성질에 비추어 보면, 공법인이 사법상 거래에 참여할 때 그 존재와 대표권이 외부에 명확히 인식될 필요가 있다는 점은 등기 근거를 인정해야 할 규범적 요청의 기초가 된다. 이는 법적 근거의 도출이라기보다 해석 방향의 결정에 관한 실질적 논거로서, 제1・2층의 근거가 긍정적으로 작용할 때 이를 강화하는 기능을 수행한다. 이 구조에서 핵심적인 역할을 하는 것은 민법 제49조・제54조・제60조이다. 민법 제49조를 특수법인에 보충 적용한다는 것은 단순히 '등기할 수 있는 사항의 목록'을 가져오는 데 그치

지 않는다. 그것은 곧 대표권 공시와 대항력의 실체법적 구조를 함께 불러오는 일이다.[58] 특히 고액의 부동산 매매나 담보 설정에서 대표권 분쟁은 곧바로 계약의 효력 다툼, 담보권 실행 과정의 분쟁으로 이어질 수 있으므로, 거래안전과 책임배분의 관점에서 설립등기의 법적 근거를 긍정적으로 해석할 필요성은 더욱 크다.

이상의 3층 위계 구조를 종합하면, 준용규정 없는 특수법인에 대해서도 설립등기의 법적 근거는 현행 실정법의 해석으로부터 도출된다. 이 근거는 등기의 절차적 가능성을 넘어, 민법 제49조・제54조・제60조가 예정하는 대표권 공시와 대항력의 실체법적 보호를 작동시키기 위한 전제조건으로서의 의미를 가진다. 다음 장에서는 이 전제 위에서, 등기가 가지는 구체적 효력의 내용과 구조를 분석한다. 이를 정리하면 다음 <표 Ⅳ-1>과 같다.

〈표 Ⅳ-1〉 준용규정 없는 특수법인 설립등기에 관한 누적적 근거 구조

층위	내용	주요 법원(法源)	부동산거래 관점에서의 의미
제1층 (실정법)	・비송사건절차법 제67조 ・법인 및 특수법인 등기규칙 ・사법등기심의관 선례에 의한 설립등기 허용 구조	・비송사건절차법 ・등기규칙 ・선례	설립등기 “가능성”을 열어 부동산거래에서 대표자・대표권 제한을 등기부로 확인할 제도적 접점 마련
제2층 (체계)	민법 제33조 이하의 ‘법인 일반’ 규율과 직능단체법 간 준용 규정의 비일관성에 대한 체계적 정합성 논증	・민법 ・개별 직능단체법	동일 유형 특수법인 간에 설립등기 가능 여부가 우연에 좌우되지 않도록 공시체계를 정합적으로 정렬
제3층 (실질)	・대표권 공시 ・대표권 제한 대항 ・거래비용・분쟁위험 감소라는 거래안전・책임배분의 요청	・거래 현실 ・정책 판단	부동산 처분・담보 설정 등 고액거래에서 특수법인이 비법인 사단보다 더 열악한 공시기반을 갖지 않도록 보완

58) 민법 제49조, 제54조, 제60조; 대법원 2002. 6. 14. 선고 2001다75677 판결. 비영리법인에서 대표권 제한의 등기 여부에 따른 대항력 구조와 거래안전 기능에 관하여는 고상현, 앞의 논문, 22-33쪽.

2. 2021비단10 결정과 선례변경의 재구성

2.1 재판부 판시의 분석

서언에서 본 바와 같이, 대한변호사협회는 2013년 설립등기 이래 312건의 변경등기를 수리받아 온 상태에서 2021년 등기관의 각하처분에 직면하였다. 재판부는 네 가지 근거를 제시하였다.[59] 첫째, "법인에 관한 민법 제3장의 규정은 모든 종류의 법인 나아가 모든 종류의 단체에 적용되는 일반법이라고 보아야 하고, … 준용규정이 없더라도 그것이 민법 준용을 배제하는 취지라고 단정하기 어렵다." 둘째, "신청인은 공법인에 해당하나 … 민법상 비영리 사단법인의 성격도 함께 가지고 있다. … 변호사법 제78조부터 제87조까지의 규정은 … 충분하지 않으므로, 민법의 사단법인에 관한 규정으로 이를 보완할 필요성이 있다." 셋째, "법인등기제도의 공시를 통하여 법인은 스스로 그 존재에 대한 대외적 신용을 확보할 수 있으며 … 제3자는 법인의 실체를 확인할 수 있게 된다." 넷째, 구 변호사법의 제정 시기가 현행 민법 시행 이전임을 지적하면서, 연혁적으로도 등기 규정 부재는 배제가 아닌 사정에 불과하다고 판단하였다.

재판부가 대한변호사협회에 대하여 "공법인"이면서 "비영리 사단법인의 성격도 함께 가지고 있다"고 한 것에 대해, Ⅱ.3에서 분석한 공법인의 이중적 법적 성질을 법원이 확인한 최초의 설시로 보는 견해도 존재한다.[60]

---

59) 서울중앙지방법원 2021. 4. 15. 자 2021비단10 결정.

60) 법조신문, 박시형, "[판례평석] 대한변호사협회 법인변경등기신청 각하결정에 대한 이의사건", 2025. 2. 26, <https://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=32801>, 검색일: 2026. 3. 11.

2.2 결정에 대한 비판적 검토

이 결정은 준용규정 없는 특수법인에서도 설립등기가 가능하다는 점을 확인한 최초의 법원 판단이라는 의의를 가지나, 다음과 같은 비판적 검토가 필요하다.

첫째, 재판부가 민법 제3장을 “모든 종류의 법인”에 적용되는 일반법이라고 설시한 것은, 민법 제3장의 적용 범위에 관한 종래 학설의 대립(보충적용설 vs. 유추적용설 vs. 직접적용설)을 충분히 검토하지 않은 채 결론을 내린 것으로 보인다.

둘째, 2021비단10 결정 자체는 감사의 등기 여부를 직접 판단한 것은 아니다. 감사 등기의 문제는 이후 사법등기심의관 제3387호 선례변경에서 이사와 감사의 등기 가능성을 구별하면서 구체화되었다. 따라서 이 부분의 쟁점은 결정례의 판시사항이라기보다, 결정례의 민법 보충적용 논리가 선례변경에서 등기사항별로 어떻게 제한되는가의 문제로 이해되어야 한다. 어떤 등기사항이 특수법인의 ‘성질에 반하는지’ 여부를 판단하는 구체적 기준이 제시되지 않았다.

셋째, 2021비단10 결정은 비송사건 결정으로서 대법원 판례와 같은 일반적 구속력을 갖는 것은 아니며, 아직 대법원 차원의 판단이 충분히 축적되지 않은 상태이다.

이와 같이 이해할 때 2021비단10 결정과 그 이후의 제3387호 선례변경은 사법상 거래관계와 직접 관련되는 대표기관에 관한 사항에 한하여 등기를 허용한 것으로 재구성할 수 있다. 그럼에도 이 결정이 확인한 법리 — 민법의 일반법적 지위, 공법인에 대한 민법 보충 적용의 필요성, 등기의 거래안전 기능 — 는 제3387호에 의해 등기실무의 공식적 입장으로 채택되어 규범적 의미를 가진다. 다만 이 결정과 선례변경은 등기의 가능성을 확인하는 데 머물렀을 뿐, 그 효력은 명시적으로 판단하지 않았다. 이 공백이 다음 장의 출발점이다.

이상과 같은 누적적 등기 근거론에 따르면, 준용규정 없는 특수법인에 대한 설립등기는 비송사건절차법・등기규칙・선례에 의해 실정법적으로 인정되고, 그 체계적・실질적 정당성은 부동산거래에서의 대표권 공시와 대항력 확보라는 관점에서 뒷받침된다. 다음 장에서는 이러한 근거 구조 위에서 특수법인 설립등기가 구체적으로 어떠한 이원적 효력(공시적 효력과 대항요건적・권리보충적 효력)을 가지는지를 살펴보고, 등기청구권의 법적 성격과 행사 경로를 검토한다.

Ⅴ. 설립등기의 이원적 효력과 등기청구권

준용규정 없는 특수법인에 대하여 설립등기가 가능하다고 하더라도, 그 등기가 부동산거래를 포함한 사법상 거래에서 어떠한 법적 효과를 갖는지가 설명되지 않으면 등기제도의 실질적 기능은 확보되지 않는다. 대표권과 그 제한의 공시, 등기사항 일반의 제3자 대항 구조가 구체적으로 어떻게 작동하는지를 밝히는 효력론이 뒤따라야 비로소 설립등기 근거론이 거래안전의 관점에서 의미를 가지게 된다. 이하에서는 설립근거법 차원의 공시적 효력과 사법상 거래 차원의 대항요건적・권리보충적 효력을 구별하는 이원적 효력론을 제시하고, 이를 토대로 등기청구권의 법적 성격을 검토한다.

1. 설립근거법 차원의 공시적 효력

특수법인은 설립근거법에 의해 법인격을 부여받는다. 이 차원에서 설립등기는 법인격의 발생요건이 아니라, 이미 존재하는 법인의 외형을 외부에 표시하는 공시적 기능을 수행한다. 이러한 구조는 Ⅱ.3.2에서 본 독일의 공법인 구조 — 설립행위에 의해 법인격이 발생하고, 상업등기부

나 사단등기부의 등기가 성립요건으로 요구되지 않는 구조 – 와도 기능적으로 상응한다. 다만 이러한 설립근거법 차원의 공시적 효력만으로는 부동산거래와 같은 사법상 거래에서 요구되는 대표권 공시와 대항력 구조가 충분히 설명되지 않으므로, 별도의 효력 차원을 구별할 필요가 있다.

2. 사법상 거래 차원의 대항요건적・권리보충적 효력

이하에서 사용하는 '대항요건적・권리보충적 효력'은 Ⅱ.4에서 도입한 '거래법적 보충효'를 그 기능적 구성요소(대항요건 기능과 권리보충 기능)에 따라 풀어 부르는 명칭이며, 양자는 동일한 효력을 가리킨다.

2.1 핵심 조문: 민법 제49조・제54조・제60조

사법등기심의관 제3387호가 민법 제49조를 준용규정 없는 특수법인에도 적용할 수 있다고 확인한 것은, 민법의 등기 관련 규정, 특히 제54조의 설립등기 이외 등기사항에 관한 대항요건 구조와 제60조의 이사 대표권 제한에 관한 대항요건 구조를 함께 고려해야 함을 의미한다.[61]

민법 제49조는 등기사항으로 목적, 명칭, 사무소, 설립허가의 연월일, 자산의 총액, 이사의 성명・주소, 이사의 대표권 제한 등을 규정한다. 다만 "설립허가의 연월일"은 주무관청의 허가에 의해 설립되는 민법법인을 전제한 것이므로, 법률에 의해 직접 설립되는 특수법인에 대해서는

61) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2001다75677 판결; 제3387호 선례. 요컨대 민법 제49조는 등기 '사항'을, 제54조・제60조는 등기된 사항의 '효력'을 각각 규율한다. 사항(무엇을 등기하는가)과 효력(등기하면 어떤 법적 결과가 발생하는가)은 불가분의 관계에 있다. 등기사항만 인정하고 그 효력을 부정하는 것은 등기의 내용 없는 형식만을 허용하는 것이어서, 등기제도의 목적에 반한다. 따라서 제49조의 보충 적용이 긍정되는 이상, 같은 법인등기 규율 체계를 구성하는 제54조・제60조의 보충 적용 역시 논리적으로 수반된다.

등기규칙 제6조 제3항의 “성질에 반하지 않는 한”이라는 한정에 의해 설립근거법의 시행일 등으로 대체 적용될 수 있다. 민법 제54조 제1항은 설립등기 이외의 본절의 등기사항은 등기 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다고 규정하여, 설립등기 이후 등기사항의 일반적 대항요건 구조를 제시한다. 민법 제60조는 이사의 대표권 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다고 규정하여, 대표권 제한에 관하여 별도의 대항요건을 명시한다. 판례는 대표권 제한이 정관에 기재되어 있더라도 등기되지 아니하면 선의는 물론 악의의 제3자에게조차 대항할 수 없다는 입장을 일관되게 취해 왔다.

이러한 조문 구조는 설립등기가 가능해진 특수법인에 대해서도, 대표권 제한과 등기사항 일반에 관한 공시·대항 구조를 부동산거래를 포함한 사법상 거래에서 일관되게 작동시키기 위한 실체법적 기반을 제공한다.

2.2 등기부 부재의 실체법적 귀결

이 세 조문의 구조에 비추어 볼 때, 등기부가 없는 특수법인은 제49조에 의한 기본 사항의 공시, 제60조에 의한 대표권 제한의 대항력 확보, 제54조에 의한 등기사항 일반의 제3자 대항이 모두 작동하지 않게 된다. 이러한 상태가 거래 실무에서 야기하는 구체적 장애는 Ⅲ.3.4에서 확인한 바와 같다. 이는 단순한 절차상의 불편을 넘어, 등기부가 부재하면 민법 제60조가 예정하는 대표권 제한의 등기가 이루어질 수 없고, 그 결과 선의·악의를 묻지 않고 제3자에게 대항할 수 없게 된다.[62] Ⅱ.1.3에서 제기한 법인격의 상대화 논의에 비추어 보면, 등기부 없는 특수법인은 법인격은 있으되 사법상 거래질서에서 그 법인격이 완전하게 기능하지 못하는 상태에 놓이게 된다. 본고에서 말하는 ‘불완전한 법인격’이란, 법률상 법인격이 부여되어 있음에도 불구하고 대표권 공시와 대항력

62) 박기주, 앞의 논문, 407쪽; 이혜진, 앞의 논문, 35쪽.

확보를 위한 제도적 장치가 결여되어, 민법이 예정하는 거래상 보호가 실현되지 못하는 상태를 가리키는 서술적 작업 개념이다. 특히 부동산의 취득・처분, 담보권 설정, 장기 임대차 체결과 같은 고액・고위험 거래에서는 대표자와 대표권 제한의 존재를 등기부를 통해 신속하게 확인할 수 없을 경우, 거래 상대방이 내부자료 확인과 보완 약정을 통해 위험을 부담하거나, 반대로 단체 내부의 통제장치가 실질적으로 무력화되는 결과가 발생할 수 있다.

2.3 대항요건적・권리보충적 효력의 정의와 이원적 효력론의 종합

현행 민법의 구조에서 제60조의 대표권 제한 대항과 제54조의 등기사항 일반 대항은 모두 등기를 통해서만 발생한다. 정관에 대표권 제한이 기재되어 있더라도, 등기되지 않은 이상 선의・악의를 불문하고 제3자에게 대항할 수 없다는 것이 확립된 판례법리이다. 즉 민법의 현행 규율체계에서 등기는 대항력 발생의 배타적 요건이며, 정관의 공증이나 주무관청의 확인 등으로 대체될 수 없다. 이 점에서 특수법인의 설립등기는 사법상 거래주체성의 보충적 완성을 위한 불가결한 법적 전제가 된다. 따라서 사법상 거래 영역에서 특수법인의 설립등기는 대항요건적・권리보충적 효력을 가진다. 이는 다음과 같이 정의된다.

특수법인의 설립등기가 사법상 거래 영역에서 가지는 효력은, 설립근거법에 의해 이미 부여된 법인격을 전제로, 대표권 공시・대표권 제한의 대항력 확보・등기사항의 제3자 대항이라는 사법상 거래주체성을 보충적으로 완성하는 것이다.

이 효력은 민법 제33조의 ‘성립요건적 창설’(법인격 자체의 발생)과 구별된다. 특수법인의 법인격은 설립근거법에 의해 이미 발생하였으므로, 사법 영역에서의 등기는 법인격을 무에서 유로 만드는 것이 아니다. 또한 단순한 ‘공시적 효력’과도 구별된다. 사법 영역에서의 등기가 없으

면 민법 제60조가 예정하는 대표권 제한의 등기가 이루어질 수 없고, 그 결과 선의·악의를 묻지 않고 제3자에게 대항할 수 없게 된다. 등기는 이러한 대항력 구조가 현실에서 작동하도록 하는 법적 전제이므로, 대표권 제한과 그에 대한 제3자 대항력 사이의 법적 연결을 매개하는 제도적 장치로 기능한다. 결국 설립근거법 차원의 공시적 효력과 사법상 거래 차원의 대항요건적·권리보충적 효력이 결합되어, 특수법인의 설립등기는 이원적 효력을 가진다.

다만 본 논문이 말하는 대항요건적·권리보충적 효력은 설립등기가 법인격 자체를 새로이 창설하거나 법률행위의 유효·무효를 직접 좌우하는 의미의 실체법적 창설효를 주장하는 것은 아니다. 이미 설립근거법에 의해 부여된 법인격과 실체적 권리의 존재를 전제로 하여, 대표권과 그 제한, 등기사항 일반에 관한 공시·대항 구조를 민법 제54조·제60조에 따라 실제 거래질서 속에서 작동시키는 범위에서의 거래법적 효력으로 한정된다.

2.4 이원적 효력론의 분리 기준과 경계 사례

이원적 효력론에 비추어 보면, “성질에 반하는지 여부”의 판단 기준은 다음과 같이 구체화될 수 있다. 등기사항이 설립근거법 고유의 공법적 기능에 전속하는 사항, 예컨대 감독관청의 인가번호나 위탁받은 공행정 사무의 범위와 같이 공권력 행사의 내용과 직결되는 사항이라면, 이를 민법상 등기사항으로 포섭하는 것은 “성질에 반하는” 것으로 보아야 한다. 반면 명칭·사무소·대표기관·대표권 제한과 같이 사법상 거래 주체성의 확인과 직접 연결되는 사항은, 민법 제49조·제54조·제60조가 예정하는 등기사항에 해당하므로 특수법인에 대하여도 “성질에 반하지 않는” 범주에 속한다고 볼 수 있다.

이때 이원적 효력론의 분리 기준은 적용 법규의 차이이다. 설립근거

법(변호사법, 의료법 등)이 직접 규율하는 법률관계 — 법인격의 부여, 회원 자격, 징계, 감독 — 에서는 등기가 공시적 효력에 그친다. 민법이 보충적으로 적용되는 사법상 거래관계 — 부동산 매매, 금융거래, 계약 체결 — 에서는 등기가 대항요건적·권리보충적 효력을 가진다. 이 기준은 경계 사례에서 시험된다. 다음 표는 이를 구체화한 것이다.

〈표 V-1〉 적용 법규에 따른 분리 기준 예시

등록 수수료 수취	대한변호사협회가 변호사등록과 관련하여 수수료를 수취하는 행위는 공적 기능의 수행에 부수하는 것이므로 설립근거법의 영역에 속하며, 등기의 대항요건적 효력이 문제되지 않는다.
회관 건물 매매	대한변호사협회가 변호사회관 건물의 매매계약을 체결하는 경우에는 민법이 적용되는 사법상 거래이므로, 등기가 대항요건적 효력을 가진다.
국유재산 관리 위탁	특수법인이 국유재산 관리를 위탁받아 체결하는 계약의 경우, 위탁 관계 자체는 공법관계이나 위탁에 기하여 제3자와 체결하는 개별 계약은 사법상 거래에 해당하므로, 후자에 대해서는 등기의 대항요건적 효력이 작용한다.

이 분리 기준은 관찰자의 시점에 따른 공법적·사법적 평가의 차이가 아니라, 문제되는 법률관계에 적용되는 규범영역의 차이에 의존하므로, 하나의 행위에 대해 관점에 따라 효력이 달라지는 불안정은 발생하지 않는다.[63] 오히려 설립근거법에 의한 공법적 활동과 민법이 적용되는 사법상 거래가 각각 고유의 규범영역을 가진다는 점을 전제로, 동일한 특수법인의 활동을 기능별로 구분하여 설립등기의 효력을 달리 파악할 수 있게 한다.

이 이원적 효력론은 등기관서의 설립등기 수리를 재량적 절차가 아닌 의무적 절차로 이해해야 함을 근거 짓는 해석론적 기준을 제공한다. 민법 제54조·제60조가 예정하는 대항력 구조가 작동하려면 설립등기

63) 소송상 대표권의 확인 수단과 이원적 효력론의 접점은 별도의 소송법적 분석이 요구되는 후속 과제이다. 특수법인이 원고 또는 피고로서 소송에 참여할 때 대표자의 적법성을 어떤 공시 수단으로 확인하는가의 문제는, 특히 공적 기능의 수행과 관련된 소송(예: 변호사 징계 관련 행정소송)에서 적용 법규의 분리 기준과 소송유형의 선택이 맞물려 복합적 쟁점을 형성한다.

가 전제되어야 한다는 점에서, 등기관서가 등기를 거부하면 특수법인의 사법상 완전한 거래주체성을 박탈하는 결과를 초래한다. 이 해석은 특히 부동산법적 맥락에서 설득력이 크다. 부동산 취득·처분, 근저당권 설정, 임대차 체결과 같은 거래에서는 대표권과 대표권 제한의 확인이 핵심인데, 법인등기부가 부재하면 거래상대방은 정관과 회칙, 회의록, 선임서류를 일일이 확인해야 한다. 결국 법인등기부는 특수법인의 내부 통제 구조를 외부 거래질서와 접속시키는 장치이자, 부동산등기제도의 공시·대항 체계와 특수법인 조직법제를 연결하는 접점으로서 기능한다.

3. 등기청구권의 법적 성격과 행사 경로

본고에서 말하는 등기청구권은 독립된 헌법상 기본권의 창설을 주장하는 것이 아니라, 설립근거법에 의해 이미 법인격과 실체적 권리를 부여받은 특수법인이 사법상 거래질서에서 그 권리를 실질적으로 행사하기 위하여 등기제도에 접근할 수 있어야 한다는 의미에서의 절차적 권리 내지 절차적 지위를 가리킨다. 등기신청 자체가 부정되거나 등기관의 재량적 거부에 맡겨지는 구조가 유지된다면, 특수법인은 법인격을 형식적으로 보유하고 있음에도 대표권 공시와 대항력 확보라는 거래법적 보호로부터 구조적으로 배제될 위험이 있다.[64]

3.1 우리나라: 성질설과 법인의 절차적 권리

현대 헌법 질서 하에서 법인이 일정한 범위 내에서 기본권의 주체가

64) 요컨대 이때의 등기청구권은 부동산등기법 영역에서 물권변동을 원인으로 상대방에게 등기절차의 이행을 구하는 실체법상 등기청구권과 구별된다. 본 논문에서 사용하는 등기청구권은 등기관서에 대하여 설립등기 신청의 수리를 요구하고, 거부 또는 직권말소에 대하여 비송절차상 이의·항고로 다툴 수 있는 절차적 지위를 뜻한다. 따라서 이는 물권적 등기청구권의 개념을 확장하려는 것이 아니라, 특수법인이 법인등기 절차에 접근할 수 있는 현행법상 절차적 권리를 지칭하는 제한적 용어이다.

될 수 있음은 일반적으로 인정된다. 우리나라 헌법재판소는 "성질상 법인이 누릴 수 있는 기본권은 당연히 법인에게도 적용하여야 한다"고 판시한 바 있으며, 이를 토대로 학설은 이른바 '성질설'의 입장이 정립된 것으로 평가한다.[65]

종래 논의가 실체적 기본권에 집중된 반면, 법인의 권리주체성이 대외적으로 실현될 수 있는 제도적 기반에 대해서는 충분한 관심이 기울여지지 않았다. 설립등기제도는 바로 그러한 기반 중 하나로서, 법인의 권리주체성을 대외적으로 형성・공시하는 핵심적 제도로 이해될 필요가 있다.

다만 본고가 말하는 등기청구권은 헌법상 명문으로 보장되는 독립된 기본권 그 자체를 주장하는 것은 아니다. 그것은 이미 법률에 의해 법인격이 부여된 특수법인이 사법상 거래질서에서 완전한 법적 지위를 확보하기 위하여 현행법의 구조로부터 도출되는 절차적 권리이다. 이 절차적 권리가 보장되지 않으면, 특수법인은 설립근거법에 의해 법인격을 취득하였으면서도 민법이 예정하는 대표권 공시와 대항력 보호로부터 배제되는 결과가 된다.

이러한 점에서 등기청구권은 재산권・직업의 자유 등 실체적 기본권의 실현을 위한 전제적 제도 기반이자, 공법인이 부담하는 사회적 책임이 대외적으로 실현될 수 있도록 하는 최소한의 절차적 장치라는 점에서 간접적인 기본권적 함의를 가진다고 볼 수 있다.

3.2 등기청구권의 실정법적 기반

비송사건절차법 제67조 제1항이 특수법인에 대한 법인등기 규정의 적용을 법률 차원에서 인정하고 있고, 등기규칙이 이를 구체화하고 있는 이상, 등기관서는 법령이 정하는 요건을 갖춘 특수법인의 등기신청을

65) 헌법재판소 1991. 6. 3. 선고 90헌마56 결정, 판례집 3, 289, 295.

거부할 재량을 가지지 않는다. 2021비단 10결정은 바로 이 맥락에서 등기관의 각하처분을 부인한 것이며, 사실상 등기청구권의 존재를 전제하고 있다.

따라서 등기청구권은 비송사건절차법 제67조 제1항 및 민법의 보충적용에 의해 뒷받침되는 실정법적 절차적 권리로서, 등기관의 거부 또는 직권말소에 대하여 법인이 이를 다툴 수 있는 구체적 법적 근거로 기능한다. 이를 곧바로 독자적 헌법상 기본권으로 구성할 필요는 없다. 그러나 이미 법률에 의해 법인격이 부여되었고 실체적 권리를 보유하고 있는 특수법인에게, 그 실현을 뒷받침하는 설립등기 절차에 접근할 법적 지위가 인정되어야 한다는 점은 비송사건절차법 제67조 제1항과 민법의 보충적용 구조로부터 도출된다. 이를 부정할 경우 특수법인은 부동산 처분이나 담보권 설정과 같은 거래에서 대표권 공시와 대항력 구조에 접근하지 못한 채, 형식적 법인격만을 가진 불완전한 거래주체로 남게 된다.

3.3 등기청구권의 구체적 행사 경로

등기청구권의 구체적 행사 경로는 비송사건절차법이 규정하는 불복구조에 따른다. 이를 시각화하면 다음 <표 V-2>와 같이 정리할 수 있다.

〈표 V-2〉 특수법인 설립등기 관련 불복절차의 구조

단계	행위 주체	대상 · 결정 · 행위	근거 규정	주요 효과
1	법인	등기관의 등기신청 각하 · 거부	비송사건절차법 제119조	관할 지방법원에 이의신청 제기
2	법인	이의신청에 대한 지방법원 결정	비송사건절차법 제120조	관할 고등법원에 항고 가능
3	법인	등기관의 직권말소 결정	비송사건절차법 제119조	각하와 동일 구조의 이의 · 항고로 통제
4	법인	위법한 거부 · 말소로 인한 손해	국가배상법 제2조	손해배상청구 (사후적 구제)

이와 같은 불복 경로가 비송사건절차법에 의해 이미 마련되어 있다는 점은, 등기청구권이 단순한 이론적 구성이 아니라 현행법상 실현 가능한 구체적 권리임을 보여준다. 특히 부동산 매매나 근저당권 설정과 같이 일정한 종결 시점과 등기이전을 전제로 하는 거래에서는, 설립등기의 수리 여부가 거래 종결 가능성과 직결된다. 등기관의 거부 또는 직권말소 시도가 장기간 지속되면, 거래상대방은 대표권 확인을 위한 추가 서류 제출과 절차를 반복해야 하고, 그 과정에서 금융조달 일정과 담보 제공 계획이 지연될 수 있다. 이의신청·항고와 같은 비송절차상 구제 경로는, 특수법인의 조직법적 안정성뿐 아니라 부동산거래에서 대표권 공시 인프라를 유지하기 위한 수단으로서도 중요하다. 나아가 국가가 국세기본법 제13조에 의해 미등기 단체에도 납세의무를 부과하면서, 이미 법인격을 부여받은 특수법인의 등기를 거부하는 것은 형평의 관점에서도 정당화되기 어렵다.[66]

3.4 비교법적 논거의 보조적 지위

이상에서 서술한 등기청구권의 실정법적 기반은, 비교법적 맥락에서도 그 정당성이 보강된다. 독일기본법 제19조 제3항은 법인의 기본권 주체성을 명문으로 인정하며, 연방헌법재판소는 부분적 권리능력을 가진 조직에 대해서도 기본권능력을 인정함으로써, 실체법적 법인격과

66) 국가는 국세기본법 제13조에 따라 설립등기도 없는 단체를 세법상 법인으로 의제하여 납세의무를 부과하고 있다. 그에 비추어 볼 때, 이미 설립근거법에 의해 법인격을 부여받은 특수법인에 대하여, 부동산거래를 포함한 사법상 거래질서에서 완전한 법적 지위를 확보하기 위한 설립등기를 거부하는 것은, 의무 부과와 권리 보장의 균형이라는 형평의 관점에서 정당화되기 어렵다. 앞서 본 이원적 효력론에 따르면 설립등기는 사법상 거래 영역에서 대항요건적·권리보충적 효력을 가지므로, 등기를 거부하는 것은 곧 특수법인의 거래주체성을 제한하거나 사실상 박탈하는 결과를 초래한다. 형평 논거는 이러한 결과가 단지 절차상의 선택 문제가 아니라, 이미 부담시키고 있는 의무와 조화를 이루는 최소한의 권리 보장이라는 점을 부각시킨다.

절차적 보호 수단이 분리될 수 없다는 인식을 반영하고 있다.[67]

미국에서도 법인등기제도 대신 주 등록청에의 등록과 Certificate of Good Standing이 기능적 등가물로 작용하며, 공법인에 해당하는 정부설립법인도 이 등록 절차를 이행하는 것이 일반적이다.

나아가 대법원 2004스42 전원합의체 결정은, 자연인 영역에서이기는 하나 실질과 공적 기록의 괴리를 시정할 절차적 수단이 인정되어야 한다는 법리적 패턴을 보여준다.[68] 이들 비교법적·국내 판례적 논거는 등기청구권의 독립적 근거가 아니라, 등기 접근권 보장의 규범적 필요성이 한국법에만 고유한 구성이 아님을 확인하는 보조적 역할에 그친다.

Ⅵ. 맺음말

1. 요약

본 논문은 준용규정 없는 직능단체형 특수법인의 설립등기 문제를, 단체 내부의 절차 문제에 한정되는 것이 아니라 부동산 거래를 포함한 사법상 거래질서에서 대표권 공시와 대표권 제한의 대항 구조가 정상적으로 작동하기 위한 공시 인프라의 문제로 재구성하였다. 이를 위하여 비송사건절차법과 민법법인 및 특수법인 등기규칙, 사법등기심의관 선례를 중심으로 설립등기의 법적 근거를 누적적으로 정리하고, 설립근거법 차원의 공시적 효력과 사법상 거래 차원의 대항요건적·권리보충적 효력을 구별하는 이원적 효력론을 제시하였다. 나아가 등기 거부·말소 시도에 대하여 비송절차상 이의·항고로 다툴 수 있는 절차적 지위를

67) 권영성, "『법인의 기본권주체성』에 관한 한 시론 : A Study on the Capacity of Corporations to Enjoy Fundamental Rights", 서울대학교 법학 제35권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 1994, 95-105쪽.

68) 대법원 2006. 6. 22. 자 2004스42 전원합의체 결정.

등기청구권으로 구성함으로써, 해석론적 결론이 부동산거래를 포함한 실제 거래현장에서 작동하기 위한 절차적 경로를 함께 제시하였다.

2. 기여 가능성

법인등기부의 부재는 대표자 확인과 대표권 제한의 공시를 곤란하게 하여, 부동산 처분행위나 담보권 설정과 같은 고액·고위험 거래에서 확인비용과 분쟁위험을 구조적으로 증가시킬 수 있다. 본고의 논의는 이 문제를 개별 단체의 특수성이나 실무상 편의의 문제로 환원하지 않고, 민법이 예정하는 대표권 공시·대항 체계와의 접속 실패라는 공시제도 차원의 문제로 환원하여, 해석론적·절차적 해결 경로를 제시하였다는 점에서 의의를 가진다. 부동산거래 관점에서 보면, 준용규정 없는 특수법인에 대한 설립등기 근거론과 이원적 효력론은 대표권 공시의 표준화를 통하여 거래상대방의 확인비용을 감소시키고, 대표권 제한의 대항 구조를 회복함으로써 책임 귀속을 외부적으로 명료화하는 방향으로 공시 인프라를 재정렬하는 역할을 한다.

3. 입법적 개선 방향

입법적 개선은 단기적으로는 개별 설립근거법에 민법 중 사단법인 규정의 준용을 명문화하여, 변호사단체·의사단체 등 직능단체형 특수법인에 관한 법적 안정성을 확보하는 방향이 우선될 수 있다. 이는 현행 해석론과 선례가 확인한 설립등기 가능성을 법률 차원의 명확한 근거로 전환함으로써, 등기관의 재량적 거부 가능성을 줄이고 등기실무의 예측가능성을 높이는 효과를 가진다. 다만 동일한 구조의 문제가 향후 새로운 유형의 특수법인에서도 반복될 수 있다는 점에서, 일반법 차원의 확인 규정을 통하여 대표권 공시 및 그 제한의 대항 구조가 민법·상법

외의 법령에 따라 설립된 법인에도 일관되게 작동하도록 하는 방안도 병행하여 검토될 필요가 있다. 비교법적・정책적 논의는 이러한 입법론의 독립된 규범근거보다는 실정법상 해석 결론의 체계적 정합성과 규범적 설득력을 보강하는 보조적 논거로 제한적으로 활용되어야 할 것이다. 예를 들어, 다음 <표 Ⅵ-1>과 같은 개정안을 제언할 수 있을 것이다.[69]

〈표 Ⅵ-1〉 신구조문대비표(시안)

현 행	개 정 안
제49조(법인의 등기사항) ①~② (생략)	**제49조(법인의 등기사항)** ①~② (현행과 같음)
<제49조의 2 신설>	**제49조의 2(특수법인의 등기)** 민법 및 상법 외의 법령에 따라 설립된 법인이 사법상 거래의 주체로 활동하는 경우에는 그 법령에 다른 규정이 없더라도 명칭, 목적, 사무소, 대표기관 및 대표권 제한에 관한 사항을 등기하여야 하며, 그 효력에 관하여는 제54조와 제60조를 준용한다.

4. 한계와 후속 과제

다만 본고의 논의는 2021비단10 결정 등 비송사건 결정과 사법등기심의관 선례를 중심으로 체계화를 시도한 것으로, 향후 대법원판결의 축적

69) 이 시안에 대하여는 민법 총칙편에 특수법인 전용 조항을 신설하는 것이 민법의 체계적 순수성에 반한다는 반론이 가능하다. 민법은 민법법인(사단・재단)의 설립과 등기를 규율하는 법률이지, 특별법상 법인의 등기까지 포섭하는 법률이 아니라는 것이다. 그러나 민법 제33조 이하가 이미 '법인 일반'에 관한 규율로 기능하고 있고, 비송사건절차법 제67조가 특수법인에 대한 민법 등기 규정의 적용을 법률 차원에서 열어두고 있는 이상, 그 내용을 민법에 확인적으로 명문화하는 것은 체계적으로 정당화될 수 있다. 나아가 비송사건절차법이나 등기규칙의 개정만으로는 제54조・제60조의 대항력 구조를 특수법인에 직접 연결하기 어렵다는 점에서, 민법 차원의 확인 조항이 필요하다. 더 나아가 비송사건절차법이나 등기규칙의 개정은 등기의 절차적 가능성을 넓히는 데 그치며, 민법 제54조・제60조의 대항력 구조를 특수법인에 직접 연결하는 실체법적 효력은 민법 조문의 적용에 의해서만 발생한다. 이 점에서 민법 차원의 확인 조항은 절차법의 개정과 별도로 실체법 수준에서 마련될 필요가 있다.

에 따라 “성질상 허용되지 아니하는 경우”의 구체 기준과 공법·사법이 혼합되는 경계 사례의 유형화가 추가로 정교화될 필요가 있다. 또한 준용규정 없는 특수법인의 설립등기에 관한 이원적 효력론과 등기청구권 구성은 부동산거래를 포함한 사법상 거래영역에 초점을 둔 해석론으로서, 공법적 관계에서의 공권력 행사 통제와의 접점, 상법상 회사형 특수법인에 대한 적용 범위 등은 향후 별도의 연구가 요구된다. 그럼에도 본고가 제시한 해석론과 입법론은 특수법인의 설립등기를 부동산거래 안전과 책임귀속의 공시 인프라로 재위치시키는 하나의 출발점으로서 의미를 가질 것이다.

참고문헌

1. 단행본

김준호, 민법강의 제25판, 법문사, 2019.

성낙인, 헌법학 제23판, 법문사, 2023.

한수웅, 헌법학 제13판, 법문사, 2024.

髙中 正彦, 弁護士法概說 第5版, SANSEIDO, 2020.

2. 학술지

고상현, “비영리법인에서 계약상의 제 문제”, 재산법연구 제36권 제4호, 한국재산법학회, 2020, 1-41쪽.

권영성, “『법인의 기본권주체성』에 관한 한 시론 : A Study on the Capacity of Corporations to Enjoy Fundamental Rights”, 서울대학교 법학 제35권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 1994, 94-111쪽.

권 철, “한국 민사법 상의 法人論”, 민사법학 제77권, 한국민사법학회, 2016, 289-300쪽.

김승열, “특수법인의 설립등기에 관한 입법론적 고찰”, 월간법제 제2009. 2월호, 법제처, 2009, 5-14쪽.

김승환, “법인의 기본권 주체성”, 고시계 제47권 제2호, 고시계사, 2002, 4-15쪽.

남효순, “민법상 이사의 대표권제한”, 서울대학교 법학 제50권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2009, 129-165쪽.

류승훈, “민법상 조합에 대한 권리주체성 및 당사자능력의 인정과 관련하여”, 민사소송 제11권 제1호, 한국민사소송법학회, 2007, 101-124쪽.

류철호, “특수법인의 설립준비규정에 관한 검토”, 월간법제 제2005. 11월호, 법제처, 2005, 61-81쪽.

박기주, “등기청구권의 비교법적 의미”, 법학논고 제40집, 경북대학교 법학연구원, 2012, 405-442쪽.

송시강, “공법상 법인에 관한 연구”, 홍익법학 제20권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2019, 573-621쪽.

송호영, “법인의 권리능력”, 비교사법 제7권 제1호, 한국사법학회, 2000, 91-122쪽.

_____, “법인설립에 있어서 등기・등록제도의 개선방안 연구”, 비교사법 제16권 제4호, 한국사법학회, 2009, 1-33쪽.

_____, “한국에서의 비영리법인 및 공익법인에 관한 법정책적 개선방안”, 법학논총 제43호, 숭실대학교 법학연구소, 2019, 273-294쪽.

_____, “법인격의 형성과 발전”, 재산법연구 제38권 제2호, 한국재산법학회, 2021, 23-56쪽.

윤진수, “민법상 조합의 권리능력에 관한 독일의 동향”, 법조 제72권 제1호, 사단법인 법조협회, 2023, 35-57쪽.

이상덕, “변호사회의 법적 성질과 소송형식”, 행정법연구 제39호, 행정법이론실무학회, 2014, 27-58쪽.

_____, “대한변호사협회의 변호사등록 지연이 불법행위에 해당하는지의 판단 기준”, 대법원판례해설 제127호, 법원도서관, 2021, 445-446쪽.

이상학, “법인의 기본권능력에 관한 일고찰”, 공법학연구 제20권 제1호, 한국비교공법학회, 2019, 343-371쪽.

이혜진, “판례에 나타난 비법인사단의 유형 및 규율에 관한 입법론”, 동아법학 제71호, 동아대학교 법학연구소, 2016, 29-56쪽.

조소영, “주식회사와 정치적 표현의 자유 - 기본권 주체성 여부를 중심으로 -”, 헌법재판연구 제7권 제1호, 헌법재판연구원, 2020, 3-26쪽.

추선희/김제완, “특수법인 설립시 종전 단체의 권리・의무 승계의 범위”, 법조 제68권 제2호, 사단법인 법조협회, 2019, 431-475쪽.

3. 자료집

김가나, “특수법인의 몇 가지 등기사항 분석 및 법령규정방식의 문제점”, 2018년도 제2회 등기법포럼: 상업・법인등기의 등기사무처리 절차상 제기되는 몇 가지 문제점과 개선방안, 한국등기법학회・대한법무사협회 법제연구소, 2018, 59-97쪽.

4. 연구보고서

남효순, 「설립등기 없는 사단・재단」의 법적 규율, 법무부, 2014.

5. 웹자료

법조신문, 박시형, “[판례평석] 대한변호사협회 법인변경등기신청 각하 결정에 대한 이의사건”, 2025. 2. 26, <https://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=32801>, 검색일: 2026. 3. 11.

[Abstract]

A Study on the Legal Basis and Effects of Incorporation Registration of Special Legal Entities

-Focusing on the Dual Structure of Establishing Statutes and the Supplementary Application of General Law-

Kim, Mingyu*

Despite being established under the same Attorney-at-Law Act, the Korean Bar Association has a corporate registry entry while the Seoul Bar Association does not. This asymmetry, even though both are special corporations directly endowed with legal personality by statute, reveals a structural problem arising from the lack of a systematic account of the legal basis and effects of incorporation of special corporations. The current framework - Article 67(1) of the Non-Contentious Case Procedure Act, Article 6(3) of the Enforcement Rule on Registration of Civil and Special Corporations, and the change of practice by the Registration Review Officer (No. 3387) - gradually acknowledges the possibility of registration for special corporations but remains silent on its normative basis and legal effects. As a result, when special corporations acquire, dispose of, or encumber real

* Adjunct Professor at KAIST Graduate School of Future Strategy

property, it is difficult for counter-parties to verify the representative and any limitations on representative authority through the corporate registry, and the core functions of the registration system - publicity of representation and enforceability of limitations against third parties - cannot operate properly in real estate transactions.

This article seeks to fill this interpretive gap. It first examines the general theory of corporate formation and incorporation, the dual public-private nature of special corporations, and the legislative structure of five professional statutes (Medical Service Act, Attorney-at-Law Act, Patent Attorney Act, Certified Tax Accountant Act, Licensed Judicial Scrivener Act), including the inconsistent presence or absence of provisions that apply the Civil Code rules on corporations. In light of the regime of functional recognition for unincorporated associations, the article shows that situations in which special corporations, despite having legal personality, cannot in practice exercise rights or publicize representation due to the absence of a registry constitute an internal incoherence of the legal system. Building on this analysis, the article proposes a hierarchical doctrine of legal grounds for incorporation of special corporations lacking explicit reference provisions, drawing on the Non-Contentious Case Procedure Act and the Enforcement Rule, the Civil Code's status as a general law, inductive reasoning from legislative omissions, and the demands of transactional safety.

The article then advances a dual-effects theory according to which the incorporation of special corporations has a merely declaratory effect at the level of their constitutive statutes, but in the sphere of private-law transactions—where Articles 49, 54 and 60 of the Civil Code apply—it performs a “defensive and supplementary” function by enabling publicity of representative powers, enforceability of limitations on representation, and

opposability of registered matters to third parties. This transactional effect is distinguished from the constitutive effect of incorporation under Article 33 of the Civil Code and is conceptualized instead as the supplementary completion of the corporation's status as a private-law actor. Furthermore, the article conceptualizes a right to demand registration as a procedural right of special corporations to access the incorporation procedure necessary to activate the publicity and opposability structure just described, and identifies concrete avenues for its exercise through objections and appeals under the Non-Contentious Case Procedure Act. Finally, it outlines legislative reforms—most notably the inclusion of explicit cross-reference provisions in individual statutes and a confirmatory clause in the Civil Code—designed to ensure that special corporations can consistently connect to the core functions of the registration system, particularly publicity of representation and enforceability against third parties in real estate transactions.

[Key Words] Special Legal Entity, Incorporation Registration, Dual-Effect Theory, Opposability-Grounding Effect, Public Juridical Person, Dual Legal Nature, Representative Authority, Organizational Accountability